

從美國模範刑法典之量刑模式 論我國死刑量刑準則*

李佳玟**

摘要

近幾年來，我國法院對於死刑案件的量刑屢屢被質疑欠缺標準，這個情況並未因為最高法院積極建立死刑量刑基準而有所改變。本文認為，主因在於我國刑法第57條不足以提供審判者適當的量刑指引。本文建議我國借鏡層次清楚、內容具體之美國模範刑法典的死刑量刑模式，立法明定何為可判死刑的從重量刑情狀，例示可調整刑度的從輕量刑情狀。為了讓量刑個別化，我國應同時引進美國之刑前量刑報告制度，協助法官以活生生的社會人之角度，衡量犯罪行為人的責任，於立法時並參考美國實務的正面與負面經驗。至於我國實務提出之教化可能性，鑑於科學並無預測人類長期未來危險性的能力，本文認為應予捨棄，審判者應改在量刑最後，對個案進行量刑是否受到激情、歧視等因素影響之反身性的審查。法官更應主動將本案與其他案件進行橫向比較，以確保處罰不至於失衡。

* 投稿日：2018年9月29日；接受刊登日：2019年6月19日。〔責任校對：賴奕霖〕。

本文作者對於死刑制度的研究已有相當時日，但一直要到2018年法官學院的邀約，才開始進行死刑量刑的研究。考量到臺灣在短時間內難以廢除死刑、死刑案件在臺灣最容易引發大眾對於司法的不信任，而實務受限於現行法，難以建立一個審查層次明確，對所有審判者具有約束力之量刑準則，本文因此建議引入美國的死刑量刑模式，作為處理臺灣死刑量刑問題的起點。討論時同時羅列美國制度的優點與缺點，使這樣的外國法引入不至於盲目。本文感謝匿名審查者的寶貴建議，讓這篇文章可以往這樣的目標前進。

** 國立成功大學法律學系教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/71017091.pdf>。



關鍵詞：死刑量刑基準、模範刑法典、從重量刑情狀、從輕量刑情狀、教化可能性、情節最重大之罪。

目 次

壹、前言	三、美國聯邦最高法院對於死刑機器的調整
貳、臺灣死刑量刑方式的變化與問題	四、典範的撤銷
一、從傳統量型模式到吳燦基準	肆、建構臺灣的死刑量刑基準
二、後續的發展與問題	一、定罪與量刑程序分離
參、借鏡美國模範刑法典	二、採納從重量刑情狀與從輕量刑情狀的死刑量刑模式
一、美國模範刑法典之死刑量刑模式	三、教化可能性的去留
二、模範刑法典的影響	伍、結論

壹、前言

2016年5月，媒體刊登一則「驚世夫妻免死」的新聞¹。被控教唆女友蔡京京一起殺害蔡母，而被一、二審法院判處死刑的曾智忠（兩人其後在看守所內結婚），在更一審被改判無期徒刑。由於更一審判決在量刑部分曾經提到曾男「高中之德育及群育方面之成績優良，大學時操行成績亦良好」，以及任職航發中心期間多次記功嘉獎，認定曾男有教化可能性²，引來不少批評，譬如：「成績好就能判免死，那成績差的就該死囉？」、「考上第一志願，直接加贈免死金牌一面就對了」³、「以後開補習班要拿這種新聞出來當廣告，倘

1 楊國文，30年前在校操行好……蔡京京夫婦弑母免死，自由時報，2016年5月5日B01版。

2 參見臺灣高等法院花蓮分院104年度上重更（一）字第1號刑事判決。

3 黃哲民，「成績好 可教化」弑母驚天 竟免死，蘋果日報，2016年5月5日A01版。

若有人不知道為什麼讀書，就可說你其實是在換取免死金牌，以後殺人可以拿成績單換取免死刑」⁴。媒體指稱，多名資深法官也對此判決「直搖頭，認為被告毫無悔過之心，質疑這叫做有教化可能嗎？」⁵

蔡京京弑母案並不是唯一一個在死刑量刑上引人爭議的刑事案件。在媒體眼中，有爭議還包括被控犯下八里雙屍命案的謝依涵案。記者主張，謝依涵在被羈押時「信仰耶穌、讀聖經」，所以法院認為謝「可教化」而免死。此外，被控因被詐賭而犯下平鎮雙屍案的曾義城，是因為「抄寫佛經、捐錢建廟」，最終被輕判25年⁶。同篇報導還挑出陳昆明與龔重安兩案，說陳昆明曾宣稱「心中惡魔就是想殺人」，法官卻認為無期徒刑就可達成社會防衛的目的，不願意判死。犯下震驚社會之北投國小女童遭割喉命案的龔重安，雖然檢察官在法庭上強調龔殺人手段冷酷凶殘，無教化可能與必要，求處死刑，但法院還是留了龔一條生路。該篇報導臚列這些案件之後，總結「法官不判死刑的理由千奇百怪」，質疑我國法院的死刑判決毫無標準⁷。

質疑死刑量刑欠缺標準的不只有媒體，還有最高法院法官吳燦。他曾為文比較最高法院97年度台上字第5018號與最高法院98年度台上字第4806號這二個強盜殺人案的最高法院刑事判決，認為這兩號刑事判決在量刑上所審酌之事由並無多大差異，結果卻有判生判死的巨大差異。他發現，判處被告死刑的最高法院98年度台上字第4806號刑事判決，文字上僅多出「罪無可逭，並無值得憫恕之處，已無法教育改造，非使其與社會永遠隔離，不能達防衛社會之目的」這幾個字。他進一步認為，倘若「教化可能性」是法院死刑

4 吳仁捷，宅神諷：拿成績單換免死刑，自由時報，2016年5月5日B01版。

5 楊國文（註1）。

6 林偉信，檢求處死 法官判生 徒呼負負，中國時報，2017年6月21日A03版。

7 同前註。

量刑之重要事由，法院必須依法檢證，以實證調查方式進行評估。否則，將「導致生死判僅取決於審判者一念之迴旋，未能拉齊不同被告之間的生死線，形成不合理的無正當性差別待遇」。⁸

吳燦法官對於死刑量刑準則的關心，早在2012年底就表現出來。他受命處理第一個在最高法院進行死刑量刑辯論的案件（吳敏誠案）⁹，在準備程序中，他便對檢辯雙方提出好幾個抽象性的問題，表現出建立一般性死刑量刑準則的興趣¹⁰。不到兩個月，他與同庭法官做出最高法院102年度台上字第170號刑事判決，詳細討論死刑量刑程序與方式（被外界稱為「吳燦基準」）。該基準要求法院對於可能判處死刑的案件，必須盤點刑法第57條各款的量刑事由，並實證調查被告的教化可能性。最高法院102年度台上字第170號刑事判決做出之後，不少判決引用¹¹。只是，從近幾年的死刑案件的量刑狀況來看，量刑標準不一的問題並沒有真正被解決，有的甚至在個案中就可觀察到。以先前提到的謝依涵案為例，一審、上訴審與更一審法院於量刑時都適用吳燦基準，判處謝依涵死刑¹²。但更

8 吳燦，刑罰裁量之正當程序——以死刑量刑為中心，法律扶助期刊，50期，頁32（2016年）。

9 最高法院為了回應外界的改革壓力，宣告從2012年12月開始，就刑事二審宣告死刑的案件一律行言詞辯論。參見最高法院，新聞稿（編號：101-刑012），2012年11月16日。

10 吳燦法官的問題包括：1. 公民與政治權利國際公約第6條第2項所指涉之「非犯情節最重大之罪……不得科處死刑」，在我國刑事法體系應如何解釋及適用、2. 刑法第57條規定量刑應審酌的事由，採正面表列（共10款）。德國刑法第46條第3項「屬於法定犯罪構成事實要素之情況，毋庸再加斟酌。」之規定，於我國刑事法官量刑時應否受其拘束、3. 被害人家屬之被害感情、犯罪行為人犯後是否賠償損害等情狀，於死刑量定之影響為何。參見李艾倫，最高法院生死辯：死刑案件三審言詞辯論，全國律師，17卷7期，頁28（2013年）。

11 例如：臺灣高等法院102年度上重更（一）字第11號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院104年度上訴字第11號刑事判決、臺灣臺北地方法院104年度重訴字第10號刑事判決、臺灣臺中地方法院104年度重訴字第1251號刑事判決。

12 參見臺灣士林地方法院102年度矚重訴字第1號刑事判決、臺灣高等法院102年度矚上重訴字第44號刑事判決，與臺灣高等法院104年度矚上重更（一）字第1號刑事判決。

二審卻跳過刑法第57條各款的盤點，直接將重點放在教化可能性的鑑定上，改判謝依涵無期徒刑¹³。蔡京京弑母案也有類似的情況，一、二審的死刑判決都採用了吳燦基準，在逆轉曾智忠死刑的更一審判決中，法院卻僅在量刑部分自行挑選法院認為與死刑量刑有關的因子，對於無期徒刑的量刑做了簡要的說明，相當程度地回到吳燦基準之前傳統的量刑方式。

改判謝依涵與曾智忠無期徒刑的法院，或許認為不是下死刑判決，就不需要進行吳燦基準要求的盤點。這兩個法院似乎忽略了他們所處理的不是一般的無期徒刑案件，謝與曾兩人本被判處死刑，因此當法院要逆轉判處被告無期徒刑，理論上還是必須經過同樣的死刑量刑審查。畢竟無期徒刑應該是法官進行死刑量刑審查後，透過判決所表示的結論，而不是量刑因子檢驗之前就有的心證。即便不是所有的無期徒刑案件都需要進行同樣規模的死刑量刑審查，但死刑改判無期徒刑的案件，若要取信於人，就沒有不以同樣規模的審查以對外交代的空間。因此，當兩個法院在判決中用傳統的量刑方式改判被告無期徒刑，並未讓外界看到法官用同樣的方式進行量刑審查，其中一個還提及犯罪行為人就學成績優良，工作曾記功嘉獎，給了外界指控法院判生判死標準恣意的依據。

即便不拿這幾個改判的案件來說，在最高法院102年度台上字第170號刑事判決出來之後，雖然死刑判決的量刑說理密度整體地提高了，不少法院還是自有量刑方式。2016年之後，死刑的量刑方式又因為最高法院在幾個案件中對於教化可能性有明顯不同的想法，使得死刑量刑標準持續引發爭議。不管法院是否如媒體指控就是因為政府政策朝向廢死，所以法院想盡辦法不判死，或是法官只是想逃避判處死刑的責任，最高法院建立量刑準則之後，大眾依然認為法院死刑量刑恣意。死刑案件持續影響大眾對於司法的信任，

13 參見臺灣高等法院104年度囑上重更（二）字第3號刑事判決。

統一法院的死刑量刑標準因此成為司法改革的指標項目，有深入討論的必要。

在過去這幾年裡，死刑量刑的問題逐漸受到重視，越來越多的研究者投入此一議題的研究¹⁴。有學者認為，吳燦法官所創立的死刑量刑基準，相當程度地參照了日本最高法院1983年之永山判決所樹立的死刑量刑基準（一般簡稱為永山基準）。或許因為如此，日本法院的死刑量刑方式在臺灣受到比較多的討論¹⁵。上述研究對於臺灣死刑量刑議題的學術化有相當大的貢獻，但對於臺灣與日本死刑量刑方式相似性的強調，很容易限制了想像。本文此計畫介紹美

14 例如：賴宏信，求刑與量刑歧異性與量刑標準之探索：以2001~2008年殺人罪為例，國立中央警察大學犯罪防治研究所碩士論文（2008年）；余麗貞，臺灣地區殺人案件量刑因素之研究，國立臺灣大學政治學研究所碩士論文（2010年）；李世芬，論死刑與無期徒刑之裁量標準，國立國防管理學院法律學研究所碩士論文（2011年）；蔡彩貞，殺人罪量刑之實證研究，國立臺灣大學財務金融組碩士論文（2012年）；謝煜偉，簡評近來有關死刑案件之最高法院判決，全國律師，17卷7期，頁5-21（2013年）（以下簡稱：謝煜偉，簡評近來有關死刑案件之最高法院判決）；鄭政松，唯處死刑或無期徒刑案件之量刑界限——以臺灣近十年相關殺人案件為例，國立臺北大學社會學研究所碩士論文（2014年）；謝煜偉，「永山基準」臺灣版？——死刑量刑基準的具體化——最高法院102台上字第5251判決，台灣法學雜誌，249期，頁212-218（2014年）（以下簡稱：謝煜偉，「永山基準」臺灣版？）；廖福特，「公民與政治權利國際公約」國內法化之影響：最高法院死刑相關判決之檢視，臺大法學論叢，43卷特刊，頁911-956（2014年）；劉邦繡，生死判決與教化矯正合理期待可能之糾葛——從最高法院幾則生死判決改判案例談起，月旦裁判時報，40期，頁72-81（2015年）；張升星，謝依涵強盜殺人案判決評析——併論兩公約施行法之國內法效力，月旦裁判時報，38期，頁65-82（2015年）；謝煜偉，最高法院在死刑量刑判斷中的角色與功能：日本與臺灣的比較，收於：葉俊榮編，變遷中的東亞法院：從指標性判決看東亞法院的角色與功能，頁147-197（2016年）（以下簡稱：謝煜偉，最高法院在死刑量刑判斷中的角色與功能）；王正嘉，論死刑之裁量與界限：以兩公約與比較法為出發，臺大法學論叢，45卷2期，頁687-754（2016年）；謝煜偉，論「教化可能性」在死刑量刑判斷上的意義與定位——從最高法院最高法院102年度台上字第170號刑事判決到105年度台上字第984號判決之演變，臺北大學法學論叢，105期，頁133-186（2018年）（以下簡稱：謝煜偉，論「教化可能性」）。

15 謝煜偉，「永山基準」臺灣版？（註14），頁212-218；王正嘉（註14），頁724-730；謝煜偉，最高法院在死刑量刑判斷中的角色與功能（註14），頁147-197；謝煜偉，最高法院在死刑量刑判斷中的角色與功能（註14），頁156-180。

國法律協會（American Law Institute）透過1962年模範刑法典（Model Penal Code）所提出之死刑量刑模式，作為建構臺灣死刑量刑準則的另一個參照對象。畢竟，當代除了臺灣與日本之外，美國是唯一仍判處與執行死刑的民主國家。美國向來重視正當法律程序，美國社會存在明顯的種族與階級差異，需要具體可行、讓量刑不流於恣意的準則。在此法治與社會背景下所發展出的死刑量刑模式，是否能解決臺灣現有死刑量刑模式不能解決的問題，為現階段難以廢除死刑的臺灣找出另一條出路，值得探究。

本文以下的分析將分為三個部分，第貳部分先討論現今臺灣死刑量刑準則的狀況與問題。在這個部分，本文將爬梳吳燦基準建立前後司法實務之死刑量刑的狀況，追問為何當最高法院積極建立死刑量刑準則之後，卻依然無法減少法院死刑量刑恣意的問題。本文第參部分將介紹模範刑法典所提出的死刑量刑模式。這個部分除了介紹該模式的操作方式與時代意義之外，將進一步介紹美國採納此一模式的實踐情況。因為實務的實踐結果，可以具體顯示此一量刑模式的優點與侷限。由於美國法律協會於2009年撤銷模範刑法典的死刑條文，本文也將探究撤銷的原因，以此評估這個模式是否依然值得我國仿效。本文第肆部分將借鏡模範刑法典建構我國的死刑量刑準則，這個部分將說明採取的原因，進一步討論如何避免這個模式可能有的問題。這個部分的討論亦將參照2004年麻州州長諮詢委員會所提出之死刑制度的報告（Governor's Council on Capital Punishment: Final Report）（以下簡稱《麻州死刑報告》）¹⁶。在21世紀初，美國死刑制度因為誤判等問題，其正當性飽受質疑。有別於多數人不是支持有限度的改革，或是主張將死刑廢除，支持死刑的麻州州長Mitt Romney於2003年組成一個包括法學、鑑識專家與執

16 Massachusetts Court System Law Library, *Governor's Council on Capital Punishment Final Report*, MASS. GOVERNOR'S OFFICE (May 3, 2004), <https://www.mass.gov/media/801591>.

法者的諮詢委員會，希望能夠在既有的法學與科學研究基礎上，建構一個符合人道、正確且公正的死刑制度。該諮詢小組於2004年提出報告，關於死刑量刑的部分，即是在美國模範刑法典的模式上做出修正建議，也因此麻州死刑報告對於有意採納美國模範刑法典模式的國家有相當的參考價值¹⁷。

貳、臺灣死刑量刑方式的變化與問題

一、從傳統量型模式到吳燦基準

臺灣法院判決所呈現的死刑量刑方式，大體上以最高法院102年度台上字第170號刑事判決為分水嶺。在這號判決中，最高法院撤銷了吳敏誠殺人案的更二審判決。在該案的更三審時，高院適用最高法院指示的吳燦基準，上訴後受到最高法院的維持。由於這個案件經歷了不同的死刑量刑模式，該案的歷審判決相當適合用來說明我國司法實務死刑量刑方式的變化。

（一）傳統死刑量刑模式：說一個被告罪無可逭的小故事

讓最高法院提出死刑量刑基準的吳敏誠殺人案，其實一審法院判的是無期徒刑。兩方上訴高等法院之後，二審撤銷原判，改判被告死刑：

……審酌被告因與被害人間生有感情及財務糾紛，經多次要求復合不成，於98年12月1日多次要求與被害人見面未果，竟攜槍前往被害人工作之華盛頓托育中心，嗣與被害人相見後，因情感糾紛憤而當場持槍殺害之，案發後復攜槍逃亡數日，造成被害人家屬難以回復之傷痛，並對社

¹⁷ See Joseph L. Hoffmann, *Protecting the Innocent: The Massachusetts Governor's Council Report*, 95 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 561, 563, 566-67 (2005).

會治安危害非輕，以及其先前於 82 年間同樣因感情糾紛而殺死女友之素行，此有本院被告前案紀錄表及該案起訴書與判決書附卷可憑……，竟未能記取教訓妥適處理情感問題，而再犯本件殺人罪，告訴代理人亦在本院陳稱：『被害人家屬對於被告是生氣又害怕，怕被告出獄會對他們不利，且死者當時死亡的時間點，是在小孩寒假的時候，而死者的孩子現在又是寒假的時候，他現在的行為都常是脫序的，這整件事情對家屬的傷害太大了，被害人家屬害怕被告如果出獄，他們的生命安全會受到危害，希望庭上給與死刑的判決。』等語，而被害人所育就讀國小一年級的兒子因被害人之死，而有創傷後壓力症候群所產生的行為退化的情形等情，業經被害人之妹黃○寬在原審陳述明確……，足見被告在本案所為之殺人犯行，對於被害人家屬造成難以彌補的傷痛，為避免被告再次恣意剝奪他人生命，實求其生而不可得，有與社會永久隔離必要。公訴人具體求處極刑，並非無因。斟酌上情，就被告所犯殺人罪部分，認應量處死刑……¹⁸。

上述判決呈現幾個特徵。首先，相對於定罪部分的長篇大論，法院只以一、兩段文字說明量刑。判決中量刑的部分，不管是文字篇幅或是論證密度，都與定罪部分不成比例。量刑文字與定罪文字的差別，反映出法官對於審判程序之不同階段的看重程度。法院之所以能夠在審判與判決中用簡略的方式處理量刑，與其第二個特徵有關：雖然刑法第57條要求法官量刑時必須審酌一切情狀，尤應注意該條所列舉的各款情狀，但法院只在判決中記載影響其量刑判斷的因素，並未記載對法官不重要的量刑因子，即便那個因子在前審裁判中，是法院不判被告死刑的重要原因，理論上當上級法院不採

18 臺灣高等法院99年度上重訴字第60號刑事判決。

納下級法院重視的量刑因子，有說明的義務。上述兩個特徵綜合成第三個特徵：此種死刑裁量方式並沒有一定的層次或結構，法院只需要提供一個被告犯行冷血兇殘，被告毫無悔意的犯罪故事，就可以合理化其無法為被告求其生的決定。至於何種情況的殺人冷血兇殘可判死刑，相當程度取決於法官的主觀想法，法院並不需要列出客觀標準。此部分的判斷可能是被告的犯罪手段，也可能是被告的犯後態度，有時取決於與被告無法控制的因素，譬如被害人家屬之後的反應，吳敏誠案二審判決就特別著重於此點。

若將本案二審與一審判決的量刑文字對比（「……（被告）後因與被害人間生有感情及財務糾紛，經多次要求復合不成，於98年12月1日多次要求與被害人見面未果，竟攜槍前往被害人工作之華盛頓托育中心，嗣與被害人相見後，因情感糾紛憤而當場持槍殺害之，案發後復攜槍逃亡數日，造成被害人家屬難以回復之傷痕，並對社會治安危害非輕，以及其先前同樣因感情糾紛而殺人之素行，有該案起訴書及判決書附卷可憑……，竟未能記取教訓妥適處理情感問題，而再犯本件殺人之罪，暨其智識程度、生活狀況與被害人之關係，以及迄今未獲告訴人諒解，惟自始坦認犯行之犯後態度等一切情狀，爰量處如主文所示之刑（無期徒刑）……」¹⁹，可以發現，兩個審級的量刑結果雖然不同，著重的量刑因子不同，但量刑的方式本質上並沒有差異。若進一步對比2010年之前的死刑判決²⁰，以及其他有期徒刑的判決²¹，可發現量刑文字簡略、量刑部分只列出法官主觀認為重要的量刑因子，以及量刑欠缺層次結構，

19 臺灣士林地方法院99年度重訴字第5號刑事判決。

20 例如：臺灣高等法院臺中分院98年度上重更（五）字第46號刑事判決、臺灣彰化地方法院90年度重訴字第12號刑事判決。事實上，在2010年到2012年這段期間，仍有不少死刑判決在量刑上維持傳統形式，例如：臺灣高等法院臺南分院99年度上重更（三）字第214號刑事判決、臺灣高等法院98年度上重更（十一）字第7號刑事判決。相較之下，吳敏誠案二審比以前的判決多說明一些。

21 例如：臺灣高等法院89年度上訴字第4191號刑事判決、臺灣高等法院107年度上訴字第661號刑事判決。

都不是傳統死刑量刑獨有的特徵。至少在2010年前的很長一段時間，法院並沒有因為判決結果涉及生命的剝奪，採用不同的量刑方式。不管審判者面對死刑時內心有什麼掙扎，至少從形式上來看，法院在死刑案件上，並未採用特別的程序或是量刑標準來處理，死刑案件與一般刑事案件無異。

（二）最高法院102年度台上字第170號刑事判決：看見活生生的社會人

前述的傳統死刑量刑方式，在2010年之後逐漸轉變。那一年，死刑議題引發前所未有的政治風暴，政府重啟死刑的執行。在此之後，殺人案件的審理，法院是否判處被告死刑，往往成為媒體與人權團體的關切焦點。2009年馬政府通過兩公約施行法，國際人權公約成為律師的主張依據，最高法院也開始在可能判處死刑的案件中加入兩公約的討論²²。是否判處死刑逐漸成為判決需要特別解釋的事項，個案中死刑量刑的篇幅增加²³，死刑案件的處理開始跟其他案件有所區別。只是，量刑論證密度增加，理由內加上了兩公約，並不一定就讓量刑說理比較深入，標準比較不恣意。

最高法院在上述背景下處理吳敏誠案，只是怎樣的死刑量刑程序與量刑方式才算符合人權公約的要求，最高法院一直在摸索。在第一次收到吳敏誠案時，最高法院除了指摘二審法院僅調查被告前科，也未綜合審酌被告坦承犯罪，並積極與被害人家屬和解的情況之外，更要求更審法院應透過審判長的訴訟指揮權，讓檢辯雙方就被告科刑範圍進行辯論，認為如此死刑的量刑才能精緻妥適，死刑

22 參見最高法院99年度台上字第8223號刑事判決、最高法院100年度台上字第3447號刑事判決與最高法院100年度台上字第3790號刑事判決、臺灣臺北地院101年度重訴字第10號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院100年度矚上重訴字第1號刑事判決。不過，這些判決顯示，即便法院在判決中加入兩公約的討論，不必然有不判死的結果，法院引用兩公約，有時只是為了強調公約並不絕對禁止死刑。輿論指責兩公約是被告的「免死金牌」，其實是個誤會。

23 例如：臺灣高等法院100年度上重更（一）字第26號刑事判決（邱合成案）。

的科處才會有正當性²⁴。最高法院第二次處理這個案件時，挑出更一審的問題，包括：（1）法院不當地將被告審判中的抗辯作為量刑事由，剝奪了被告的防禦權；（2）法院並未確實回應辯護人的要求，針對刑法第57條各款進行調查審酌，也沒有注意被告在原審已提出書狀，解釋沒有賠償被害人家屬是因為經濟困窘；（3）法院在量刑時僅考慮應報主義，沒有考慮到教化的問題；以及（4）並未就本案量處死刑提出必要性的說明²⁵。只是當更二審採取與其他案件相當不同的死刑量刑程序與說理方式，包括如辯方所願，傳喚了對被告有利的證人，在判決中記載對被告有利的證詞，詳細說明判死的理由，直球回擊最高法院的發回意見，甚至引用國際人權公約與大法官解釋，合理化死刑判決²⁶，最高法院還是將更二審的判決撤銷發回，新的受命法官吳燦準備建立一個更全面的死刑量刑基準。

作為死刑量刑基準領頭羊的最高法院102年度台上字第170號刑事判決，其實在死刑量刑程序上也有重要性。最高法院在這號判決裡依據在我國已有法效力之公民與政治權利公約第6條的規定、公約人權事務委員會的意見，以及死刑終結人的一切權利，所以死刑案件的科刑必須謹慎的理由，確立刑罰裁量必須受正當法律原則之拘束的前提，指出：（1）依照刑事訴訟法第288條第3項與第4項之規定，事實審法院必須將犯罪事實與科刑的調查區分開來，避免讓與犯罪事實無關的科刑資料影響法官認定事實的心證，也避免法院刑罰裁量流於恣意。此外，（2）雖然量刑資料只需要自由證明，也沒有證據排除法則的適用，但量刑事由仍必須經過一定的調查程序，審判長應依據刑事訴訟法第288條之1第2項，告知被告得提出有利之證據；且必須賦予當事人量刑辯論，對不利的科刑資料進行

24 參見最高法院100年度台上字第2261號刑事判決。

25 參見最高法院100年度台上字第7302號刑事判決。

26 參見臺灣高等法院101年度上重更（二）字第2號刑事判決。

防禦的機會。最高法院認為，雖然刑事訴訟法第289條第3項僅賦予當事人、辯護人就科刑範圍有陳述意見的機會，但鑑於兩公約對於死刑量刑程序的要求，以及立法院審議中的刑事訴訟法修正案也有意朝向此方向修法，刑事訴訟法第289條第1項規定之法律辯論，應涵蓋法律效果（科刑）的辯論。

此號判決更被注意的是死刑的量刑方式。就此，最高法院明確指出，為確保科刑裁量之明確性與客觀性，避免因法官之恣意或任性而浮動，刑罰之裁量「……應遵守憲法位階之平等原則，公約保障人權之原則，以及刑法所規定之責任原則，法理上所當然適用之重複評價禁止原則」。此外，法院於量刑時必須「在正義報應、預防犯罪與協助受刑人復歸社會等多元刑罰目的間尋求衡平」。基於刑法第57條的規定，法院在個案考慮科處死刑的時候，必須依據行為人之罪責程度以決定法刑罰輕重，以符合罪責原則。於審酌所有對行為人有利不利的科刑因素時，尤其必須逐一檢視審酌刑法第57條所例示的10款事由，以「盤點存貨」的方式對量刑因子詳實清點，如此才能讓犯罪行為人以「活生生的社會人」而非「孤立的犯罪人」的面目呈現。此外，為了確認犯罪行為人不得不施以極刑對待，法院尚必須回答行為人何以「顯無教化矯正之合理期待可能」。就此，吳燦基準要求法院必須以實證調查方式進行評估（例如科刑前之調查報告）行為人的教化可能性，考量犯罪行為人之人格形成及其他相關背景資訊。只有在事實審法院認為無法透過終身監禁的手段防禦犯罪行為人對於社會的危險性，且依其犯罪行為及犯罪行為人的狀況，科處死刑並無過度或明顯不相稱的情況，法院才可以量處死刑。由於吳敏誠案的更二審法院並未明確區分論罪與科刑的調查、也未依法全盤審酌對犯罪行為人有利不利之因素，僅調查前案科刑的執行情形。且在犯罪行為人之教化可能性的這個問題上，僅依法官主觀判斷，而非用實證調查的方式進行評估，最高法院因而撤銷更二審的判決。

平心而論，最高法院102年度台上字第170號刑事判決所提出的一些量刑程序與方式的要求，並非此號判決首創。譬如死刑量刑辯論，最高法院在101年度台上字第4531號刑事判決（邱合成案）裡，就曾討論現行法是否足以要求法院進行死刑量刑辯論。最高法院102年度台上字第170號刑事判決的優點在於更為詳細地論證現行法的適用問題與可能性，並兼及死刑量刑程序的其他問題，給了死刑量刑比其他判決更為周延的程序框架²⁷。死刑量刑方式也有類似的情況，以邱合成案為例，最高法院在100年度台上字第3447號刑事判決裡，就以死刑具有不可回復性，要求審判者必須依據刑法第57條之規定，以行為人之責任為基礎，審酌一切情狀，尤其注意該條所列10款量刑事由。此號判決並要審判者不能只考量應報主義，還必須考慮到刑罰的教化功能²⁸，相當程度包含了最高法院102年度台上字第170號刑事判決所著重的幾個面向。最高法院102年度台上字第170號刑事判決標榜的刑法第57條各款量刑事由的盤點，以

27 事實上，死刑量刑程序仍有其他議題尚待解決，譬如：法官評議時，死刑量刑之決定是否需一致決？當第三審進行死刑量刑辯論時，被告是否有權到場，以保障其意見陳述權與聽審權？參見錢建榮，最高法院死刑量刑辯論論為「異鄉人」的審判！，全國律師，17卷7期，頁22-26（2013年）；高涌誠、黃淑芳，死刑案件與兩公約，收於：與死刑拔河：死刑案件的辯護經驗與建議，頁66-83（2015年）；王正嘉（註14），頁669-707。

28 最高法院100年度台上字第3447號刑事判決的原文為：「……公民與政治權利國際公約第6條第1項所明定：人人皆有天賦之生存權，任何人不得無理剝奪。而死刑之剝奪生命，具有不可回復性。且刑事審判旨在實現刑罰權之分配正義，故法院對於有罪被告之科刑，應符合罰刑相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪，此所以刑法第57條明定科刑時，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項，以為科刑輕重之標準。而現階段之刑事政策，非祇在實現以往應報主義之觀念，尤重在教化之功能，立法者既未將意圖勒贖而擄人，而故意殺人罪之法定刑定為唯一死刑，並將無期徒刑列為選科之項目，其目的即在賦予審判者能就個案情狀，審慎斟酌，俾使尚有教化遷善可能之罪犯保留一線生機。故法院對於泯滅天性，窮兇極惡之徒予以宣告死刑之案件，除應於理由內就如何本於責任原則，依刑法第57條所定各款審酌情形，加以說明外，並須就犯罪行為人事後確無悔悟實據，顯無教化遷善之可能，以及從主觀惡性與客觀犯行加以確實考量，何以必須剝奪其生命權，使與社會永久隔離之情形，詳加敘明，以昭慎重。」

及對於教化可能性的實證調查，也曾在其他判決中出現過²⁹。

因此，最高法院102年度台上字第170號刑事判決對於實務的意義，除了提出較先前之判決更為全面以及詳細的論證，有力地支持了自2010年來部分判決所展現之「死刑量刑方式應該與一般刑案的量刑方式不同，調查的嚴謹度必須提高，死刑的決定必須詳細說明」的取向之外³⁰，還在於其以最高法院的地位，以理論支持了特定的量刑因子調查方式——為了從活生生的社會人之角度進行量刑，法院必須以「盤點存貨」的方式清點刑法第57條10款量刑事由，並且必須以實證調查的方式評估行為人的教化可能性，後者尚且讓教化可能性成為一個必須獨立調查的量刑因子，不再只是法院綜合考量之後對於犯罪行為人的評價性結論³¹。

若對照當時的死刑判決，最高法院102年度台上字第170號刑事判決的意義有三個面向：這號判決（1）用力推了當時「死刑量刑質量應有別於一般量刑，有比較多的調查與說理」之趨勢一把；（2）要求法官對犯罪行為人進行全人格形成因素的考察，避免法官只看到犯罪手段，只看到犯罪所帶來的傷害，在量刑時只用刻板印象來觀看被告，卻不想了解被告在其所存在的社會脈絡裡為何走到現在這一步；以及（3）要求法官在決定判死之前，單獨且客觀地從「犯罪行為人是否已無法教化，無其他方法可阻止被告再犯」的

29 參見臺灣雲林地方法院100年度囑重訴字第1號刑事判決（林國政案）。

30 在2010年之後，仍有一些判決維持傳統的量刑方式，即便死刑判決成為爭議的焦點，纏訟經年的邱和順案就是這類判決。更十一審法院給了簡略的量刑理由說明死刑的決定，最高法院於駁回被告上訴的判決中，甚至沒有討論量刑，參見臺灣高等法院98年度囑上重更（十一）第7號刑事判決、最高法院100年度台上字第4177號刑事判決。

31 長久以來，教化可能性只是法官綜合各個量刑因子的結論。例如：臺灣臺北地方法院92年度重訴字第8號刑事判決：「……爰分別審酌被告錢萬枝、錢文土二人均正值壯年，竟不思循正當途徑獲取財富，……其猶不足而對並無怨隙之被害人劉增壽痛下殺手，再令其曝屍荒野，犯後更無絲毫悔意，甚且之後又另行起意再次為擄人勒贖行為，均足見被告錢萬枝惡性之重已無教化之可能，已達與社會永久隔離之地步……。」

角度，思考死刑的必要性，藉此約束法院在死刑量刑上的恣意性。因此，不管本號判決在多大程度解決死刑量刑標準不一的問題，在國家仍維持死刑時，此一判決加入了死刑案件應提高調查與說理要求的一方，其用心值得肯定。

二、後續的發展與問題

（一）量刑說理密度提升

作為最高法院開啟量刑辯論後第一個做出的判決，吳燦法官希望透過最高法院102年度台上字第170號刑事判決提供司法實務一套死刑量刑準則的企圖心是明顯的。從後續的發展狀況來看，不管死刑量刑的標準是否因此統一，死刑判決的論述質量明顯增加，2013年之後，不再有法院使用傳統的簡要敘述合理化判處被告死刑的決定。

不過，對於這個發展趨勢有促成作用的，不只有最高法院102年度台上字第170號刑事判決，其他幾個同時間在最高法院進行量刑辯論的案件也有貢獻³²。不容易被注意到，但更有實質影響力的，或許是後續像最高法院102年度台上字第5123號（沈江田案）這樣的刑事判決。在這號判決裡，最高法院雖然沒有提出自己的量刑基準，而是以下級審對於某些量刑因子的調查並不詳盡，認定方式也不妥當，將原判決撤銷發回。這號判決相當程度地例示/預示了最高法院接下來對於死刑量刑做法：積極審查下級法院的死刑量刑方式，包括事實審法院對於量刑因子的調查是否足夠³³，說理是

32 最高法院102年度台上字第446號刑事判決（陳昱安案）、最高法院102年度台上字第531號刑事判決（吳啟豪案）、最高法院102年度台上字第2392號刑事判決（林子如案）、最高法院102年度台上字第2575號刑事判決（林國政案）。

33 例如：最高法院104年度台上字第3631號刑事判決（「……然就何以認為沈文賓所言『受被害人言語刺激』係屬『謊稱』乙節，並未說明理由，乃逕以此為據，認沈文賓『尚未悔悟』，亦欠妥洽。」）

否相互矛盾³⁴，甚至是質疑某個因素是否適當作為死刑量刑因子³⁵。最高法院對於下級審的量刑方式細密地審查，不管是否出於外界或下級審所付度的廢死動機，或是出於最高法院的職責，都讓下級法院必須用更多的調查與說理，說明其生死的決定，不管是否認同最高法院的做法，死刑判決的量刑與一般刑事案件的差距因此越來越大。死刑案件的量刑需要特別處理與說理，自此成了司法實務難以逆轉的趨勢。

（二）理想與現實的落差

最高法院102年度台上字第170號刑事判決成功帶動死刑判決量刑說理密度的增加，但在其他兩個面向的影響就沒有這麼順利。之所以如此，除了最高法院102年度台上字第170號刑事判決對於其他法院並無拘束力之外，該判決所設下的基準也有內涵與適用方式不清楚的問題。譬如：刑法第57條各款量刑事由的盤點清查要怎麼進行？法院是否要依據刑法第57條各款的規定列點清查，還是對該條進行綜合評述就好？「教化可能性的實證調查」是指什麼？法院一定要委任專家進行調查，還是可以自行判斷？究竟是要證明被告「無教化可能性」，所以必須判死，還是由證明被告還有「教化可能性」，所以才不判死？證明的門檻又是什麼？

34 例如：最高法院106年度台上字第1042號刑事判決（「……至於所引被告不同版本之供述及測謊鑑定報告等內容，似亦僅係被告歷經本案警詢、偵審或鑑定全過程所為否認或抗辯之內容，縱認與法院依職權認定之事實或證據之取捨結果有所歧異或相反而不足採信，仍屬其就所涉個案基於防禦權之行使而自由陳述、辯明或辯解（辯護）之範疇，且係針對個案而為，與其平時之品德與素行仍屬有別，原判決執為認定被告品行上『向有說謊傾向』之證據資料，自非妥適。」）

35 例如：最高法院105年度台上字第1627號刑事判決（「……至於刑法第77條第1項之無期徒刑執行逾25年，因有悛悔實據，而得許假釋出獄之規定，是否該「逾25年」期間屬過短，或認為現行矯正機構之矯正效果不彰，使重大犯罪者於一定期間徒刑之執行後，立刻得以倖獲假釋，造成假釋者之再犯率偏高等，均與具體案件被告本身及其所為犯罪之情狀無關，自不宜作為量處被告死刑之不利參考因子，致脫逸罪刑相當原則。」）

理論上，吳燦基準要求法院盤點清查刑法第57條量刑因子，目的是希望法官可以對犯罪行為人進行全人格形成因素的考察，避免法官只是看到被告用了什麼手段犯罪，造成多大的傷害，並不理解被告在社會脈絡下為何走到現在這一步，不去探究在社會結構的束縛下，個人的責任究竟有多大。從這個角度來看，列點清查的方式比較能夠強迫法官對犯罪行為人的各個面向進行考察，避免法官只是選擇性地強調挑其有意義的量刑因子，驗證早已有的負面印象。此外，從文字語意來看，列點清查也比較能夠達到「盤點存貨」的要求。

至於教化可能性的調查，如果吳燦基準的目的是希望降低法官的主觀恣意性，交由其他對人類心理與行為有研究的專家，對於犯罪行為人進行客觀的人格考察與行為預測，比起法院自行調查判斷適當。雖然行為科學是否就能預測人的未來行為，這樣做是否讓渡了法院的判決責任等，本身並非沒有爭議³⁶。進一步地，如果教化可能性作為量刑因子的理論基礎是特別預防，調查目的是希望達到慎用死刑的效果，要真的「求生不可得」，那麼，在死刑量度的最後一關，該問的不只是犯罪行為人是否已經毫無改變的希望，還必須問是否完全沒有其他方式可以避免犯罪行為人的再犯。若有舉證責任之分配的話，應由檢察官舉證證明被告「無教化可能性」。如果不是到「毫無」教化可能性的地步，也起碼必須一再追問是否別無其他手段避免被告於假釋出獄時依然再犯，被告假釋時的年紀同時必須被考慮進去。

不過上述的討論只是從概念目的去設想，由於最高法院102年度台上字第170號刑事判決並沒有清楚地定義刑法第57條各款量刑事由的調查方式，也沒有明確界定教化可能性的實證調查方式與證

36 參見黃致豪，司法心理鑑定，收於：與死刑拔河：死刑案件的辯護經驗與建議，頁125-131（2015年）；謝煜偉，論「教化可能性」（註14），頁149-153。

明門檻，後續判決能否釐清變得重要。

1. 刑法第57條的盤點容易淪為過場

當吳燦法官有機會再度補充吳燦基準時，他並沒有就刑法第57條各款量刑事由的調查方式多做說明，因此只能從案件結果進行考察。他在其擔任受命法官的張鶴齡案核可了列點清查的做法³⁷，在其擔任陪席的彭建源案，接受該案更一審法院使用綜合評述的方式處理刑法第57條各款量刑事由，這個更一審判決還引用了最高法院102年度台上字第170號刑事判決³⁸。吳燦法官在其擔任審判長的吳敏誠案定讞判決裡，也接受該案更三審判決用綜合敘述的方式審查刑法第57條各款³⁹，吳敏誠案更三審判決還是最高法院102年度台上字第170號刑事判決發回更審的判決，依照實務向來的作法，會在判決中遵照吳燦基準的要求。綜合來看，吳燦法官對於如何盤點刑法第57條各款量刑事由似乎沒有非怎樣才可以的想法。

觀察2013年後的死刑判決，法院對於刑法第57條各款量刑事由的調查有採取列點的方式，也有採取綜合評述。值得注意的是，有些判決即便列點清查，但做法相當簡略。以2013年9月做出的沈文賓案的一審判決為例，宜蘭地方法院雖然採取吳燦基準，列點清查刑法第57條量刑因子，但對於可深入調查的量刑事項，說明頗為簡略（「……（2）犯罪時所受之刺激：因被害人潘○瑤未明確告知證人張○革之住處並與被告沈文賓發生爭執。……（4）犯罪行為人之生活狀況：與證人張○革分居中（現已離婚），與證人張○革所生之未成年子女現由證人張○革照顧，現與其兄弟姐妹同住，職業

37 參見臺灣高等法院103年度上重更（五）字第1號刑事判決、最高法院105年度台上字第2337號刑事判決。

38 參見臺灣高等法院102年度上重更（一）字第11號刑事判決、最高法院103年度台上字第3062號刑事判決。

39 臺灣高等法院102年度上重更（三）字第2號刑事判決、最高法院105年度台上字第1567號刑事判決。

工，家庭經濟狀況勉持。(5) 犯罪行為人之品行：少年時曾有多次竊盜並施予感化教育，101年間又因竊盜案件經緩起訴處分。(6) 犯罪行為人之智識程度：高中畢業，無精神及智力障礙。」)。之後的量刑綜合考量，也是單面向地呈現被告的惡行。這個案子一直到2018年6月做的更三審判決，高等法院在數項量刑因子的檢驗上，依然簡略（例如：「2. 犯罪時所受之刺激：丙○○：因案發當日剝奪潘女、呂男之作為仍未能達到找到張○恩之目的，欠缺理性思考而憤怒殺人。……5. 犯罪行為人之品行：（本院被告前科紀錄表）丙○○：101年間曾因竊盜案件經緩起訴處分。6. 犯罪行為人之智識程度：（見警詢筆錄受詢問人欄）丙○○：高中畢業。」⁴⁰）對照之下，吳敏誠案更三審雖然沒有列點清查，而是採取綜合敘述的方式，但內容不僅呈現被告犯罪手段、造成的傷害，尚且深入地調查了被告外觀與家庭暴力的童年經驗，對其個性、發展與異性關係的影響，以及與犯罪的關聯，相當程度在將被告放在社會脈絡下，觀察被告是如何走到殺人這一步⁴¹。

如果說盤點清查刑法第57條量刑事由的要求，是想要法官深入地了解犯罪行為人，實務的操作結果相當程度顛覆此種設想。從前一段的舉例可以看到，有些判決雖然沒有逐條盤點，但還是可以讓犯罪行為人的形象顯得立體；有些判決即便盤點刑法第57條量刑因子，因為調查膚淺，犯罪行為人的人生依然扁平。之所以如此，與刑法第57條的規定，只要求審判者調查某個面向，卻沒有規定需要調查地多深，需要多少的證據才能夠完整地說明犯罪的動機、目的等；以及條文要求審判者「科刑時以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀」，也沒有限定審酌的範圍有關。再加上我國並不像美國採行科刑前量刑調查制度，因而刑法第57條的量刑事由究竟可以調查得多深入，完全取決於辯護人與檢察官的舉證能力，以及法官的

40 參見臺灣高等法院106年度矚上重更（三）字第2號刑事判決。

41 參見臺灣高等法院102年度上重更（三）字第2號刑事判決。

調查意願。事實上，刑法第57條除了沒有說量刑事由要調查地多深入之外，也沒有告訴法官個別因素對於死刑的決定究竟是正面或是負面，這條更沒有說量刑事由之間的關係為何，要如何權衡。此外，如果說刑罰目的指引著法官的量刑⁴²，包括對於量刑因子的審查方式，吳燦基準之綜合各種刑罰目的的主張，很容易讓法官在清查刑法第57條量刑因子，隨著自己的刑罰哲學的傾向，而有不同的審查方式。舉例來說，偏向應報與一般預防的法官，容易對把被告放在社會脈絡一事欠缺真正的興趣，才會有用被告前科就來定義犯罪行為人之品行的做法，刑法第57條量刑事由的盤點很容易淪為形式。一旦刑法第57條量刑因子的審查流於形式，這部份的審查就像是個過場，欠缺實質意義。

2. 教化可能性的判斷浮動

(1) 調查方式：自己來還是找專家？

在教化可能性的實證調查方式上，吳燦法官似乎也是採取「都可以」的立場，並沒有堅持交由專家進行調查。在他擔任受命法官的張鶴齡案以及擔任審判長的吳敏誠案裡，最後一個事實審都委任具有司法心理學專長的學者對被告進行再犯風險與矯治、再社會化的鑑定，鑑定結果被告再犯風險低，矯治可能性高，這兩個判決都被最高法院維持而定讞。但是，吳燦法官陪席參與的彭建源案定讞判決，在該案最後一個事實審裡，法院自行判斷對被告的教化可能性，判斷的對象是被告於審判中的言語態度⁴³。辯護人上訴最高法院時，雖然沒有將此一部分與教化可能性相連，也沒有主張教化可

42 參閱林山田，論刑罰裁量——為紀念刑事法雜誌二十週年而作，刑事法雜誌，21卷1期，頁10-12（1977年）。

43 臺灣高等法院102年度上重更（一）字第11號刑事判決（「本院更審中仍供稱我買了10公升……的汽油去燒死5個人，你還覺得我不夠可惡嗎！那我下次有機會出去，我會做一件更可惡的事，讓你看！沒有判我死刑，如果可以出去，依我的個性我還是會殺人……。」）

能性必須由專家來判斷，但質疑事實審的法院的判斷過於粗糙⁴⁴，這其實是法院自行判斷被告教化可能性容易有的問題。然而吳燦法官為其中一員的最高法院刑事庭第四庭並沒有回應辯護人這個主張，而是維持了該案更一審的判決，駁回被告上訴，讓死刑定讞。

觀察後續的發展，實務同樣出現兩種做法，或是三種，第三種是法院委任專家之後，又自行判斷，生死的結果不一⁴⁵。在那些完全由法院自行判斷的案件裡，法院的說理很容易引發輿論的批評。譬如先前提到的蔡京京案，關於共犯曾智忠的教化可能性，法院並未特別論述，僅把被告曾智忠的學歷、職業、高中之德育及群育方面之成績優良，大學時操行成績亦良好，工作時曾有嘉獎記功列入量刑事由，於結論中認定被告「非無教化之可能性，其行徑尚未達應與世永久隔離之程度⁴⁶。」此一論述方式被輿論批評成績好就可免死。

除了理由常讓一般人難以接受之外，法官自行判斷教化可能性很容易出現標準不一致的情況。譬如：陳昱安犯罪後供稱：「『後悔不存在我心中。』、『(問：對其他家人之想法？)恨之入骨，我也想對他們行兇。』」，被告被認為欠缺教化可能性而被判死⁴⁷。但在吳啟豪案，即便被告曾咆哮法庭，揚言出獄後將對家人不利，但法官參酌其他因素（被告在羈押期間曾幾次表達懺悔的言行，且親人

44 辯護律師於上訴批評原審：「上訴人於原審陳明：『沒有判我死刑，如果可以出去，依我的個性我還是會殺人』，即明上訴人本身具有負面、自我放棄思想之精神病患，其上開言語，顯然為達一意求死之目的，符合『憂鬱異常』症狀所表現之『借警自殺』，原判決據以認定上訴人犯後態度不佳，進而判處死刑，有悖於論理法則等證據法則之違法。」參見最高法院103年度台上字第3062號刑事判決。

45 譬如：最高法院102年度台上字第2575號刑事判決（林國政案）、臺灣高等法院花蓮分院103年度上重更（四）第1號刑事判決、最高法院103年度台上字第3113號刑事判決（沈江田案）。

46 參見臺灣高等法院花蓮分院104年度上重更（一）字第1號刑事判決。

47 臺灣高等法院100年度上重訴字第41號刑事判決，為最高法院102年度台上字第446號刑事判決支持。

仍持續與被告互動，並沒有放棄被告），判斷被告在法庭上的話只是「自暴自棄之情緒性言詞」，認定被告具有教化可能性，改判被告無期徒刑⁴⁸。然而到了彭建源案，針對被告在法庭上宣稱要繼續殺人，律師認為這是被告自我放棄，罹患憂鬱症的表現，法院卻不理會這樣的主張⁴⁹。

由法院自行判斷爭議不斷，但並非由專家進行判斷的案件就可免於批評。例如：吳敏誠案改判無期徒刑的判決一作出時，立即引發輿論的抨擊，即便有專家的背書。吳敏誠案中最高法院發回了數次，最後更三審下級法院改判無期徒刑，被最高法院維持定讞的紀錄，讓輿論批評最高法院只是為了要一個不判死刑的結果，因此發明了另一個挑惕下級法院判決的方式⁵⁰。而當謝依涵案，法院以專家鑑定謝依涵再犯可能性低，矯治可能性高，因而改判謝依涵無期徒刑定讞的判決，毫無意外地引發輿論的質疑。外界抨擊被告是否判死，變成是由專家來決定，「教化可能性」儼然成為某些被告的免死金牌⁵¹。雖然不同做法的調查範圍與密度大不相同，但從結果來看，同樣給大眾留下「教化可能性」讓法官可操弄死刑判決的印象。

（2）定位更動與判斷標準不明

至於「教化可能性」在死刑量刑的位置，吳燦法官倒是曾在最高法院102年度台上字170號刑事判決裡明確主張，法院若要判處被告死刑，必須確認被告「無教化可能性」，對於教化可能性的定位

48 參見最高法院102年度台上字第531號刑事判決。

49 參見最高法院103年度台上字第3062號刑事判決。

50 參見朱學恒，亂世殺人犯的免死金牌——有教化之可能，ETtoday論壇，2016年9月20日，<https://www.ettoday.net/news/20160920/778455.htm#ixzz5NEZDTXiW>（最後瀏覽日：2018年8月4日）。

51 例如：許文彬，「教化可能」豈是免死金牌，中國時報，2017年1月18日A10版。

是「選科死刑事由」⁵²。只是在同年年底的最高法院102年度台上字第5251號刑事判決（張鶴齡案）裡，吳燦法官改為要求法院調查犯罪行為人是否具有「教化可能性」，教化可能性從法院的「選科死刑事由」轉變成被告的「死刑迴避事由」⁵³。這個立場在吳燦法官擔任受命之最高法院105年度台上字1567號刑事判決（吳敏誠案），以及擔任審判長之最高法院105年度台上字2337號刑事判決（張鶴齡案）再度被確認。

這個立場的轉變，對於被告的影響，關鍵點其實在於判定的門檻。理論上，死刑選科事由說比死刑迴避事由說對被告有利。倘若採死刑選科事由說，只要被告不能被證明「無教化可能性」，或是不能證明沒有其他方法可以避免被告再犯，法院就不應當量處被告死刑，「無教化可能性」是死刑的必要條件之一。但若採死刑迴避事由說，一旦被告不能被證明「有復歸社會之更生可能性」，法院就不能迴避死刑的科處。將教化可能性當作死刑迴避事由，雖然還是為「尚有教化遷善可能之罪犯保留生機」，但流露的是對於「該死之人」例外恩赦的態度。如果加上舉證責任的分配，採取死刑迴避事由說時，被告必須證明自己還有教化可能性，將會加重被告的負擔。但是，倘若採死刑迴避事由說時，只要被告能被證明有教化

52 最高法院102年度台上字170號刑事判決：「從而犯罪行為人何以顯無教化矯正之合理期待可能，而不得不施以極刑對待，必須考量犯罪行為人之性格形成及其他相關背景資訊，以實證調查方式進行評估（例如科刑前之調查報告），如科處死刑必也已達無從經由終身監禁之手段防禦其對社會之危險性，……再就所謂上訴人『無教化可能性』部分，原判決僅以上訴人已有前案受刑經驗，仍然未改本性，其性格已定型，據以推認即便上訴人長期在監執行仍有再犯之虞，為屬無從教化矯正之徒。」

53 最高法院102年度台上字第5251號刑事判決：「死刑應儘可能謙抑適用，必以在罪責原則之基礎上，綜合刑法第57條所列10款事項等有利與不利之情狀為評價後，已足認被告具體個別犯罪情節、所犯之不法及責任之嚴重程度，其罪責誠屬重大，無論自罪刑均衡之觀點抑或自一般預防之觀點，均認為處以極刑為不得已之情形者，始允許死刑之選擇。亦即，於此仍尚應考量有無足以迴避死刑適用之被告復歸社會之更生可能性。」

可能性就能滿足舉證責任，對於被告的不利程度，不一定大於採取死刑選科事由說時，檢察官只需要證明「犯罪行為人顯無教化矯正之合理期待可能」。只是吳燦法官在上述四個判決中，只有最高法院102年度台上字第170號刑事判決中提及法院必須調查犯罪行為人是否顯無教化矯正之合理期待可能，其他三個改採死刑迴避事由說並對舉證標準並未有所討論，這使得法院在使用教化可能性這個概念時，存在自行詮釋適用的空間，不必然有相同的標準。

過去這幾年，與其說死刑迴避事由說是通說，不如說寬鬆判斷標準是通說，除非專家明確指出被告矯治可能性高，再犯可能性低，犯行重大的被告才會有判處無期徒刑的機會，吳敏誠案、張鶴齡案與謝依涵案都是這樣。也有判決標準嚴格，例如在臺灣高等法院102年度上重更（一）字第8號刑事判決（陳昆明案）裡，面對被告並非毫無矯治可能性，但是我國矯治制度卻難以被仰賴能夠教化被告，避免其再犯的窘境，法院主張「不能遽認係被告無教化之可能性，而逕以剝奪其生命」，這個判決受到最高法院的支持而定讞⁵⁴。

或許因為教化可能性之鑑定結果將會影響一個人的生死，受委任的專家態度有越來越謹慎的趨勢。面對專家的謹慎，有法院選擇不理會「不排除被告有教化可能」這樣的鑑定意見。譬如：臺灣高等法院106年度矚上重更（三）字第2號刑事判決（沈文賓案），面對一個專家（臺大醫院）對於被告有教化可能性模稜兩可的意見（「倘能窮盡一般輔導治療之處遇，目前仍無法排除沈員……接受教化導正之可能」），另一個專家（監獄教誨師）提出「被告有改過遷善意願」的證詞，法院選擇無視關於國家制度的提問，將重點放在

54 參見最高法院104年度台上字第717號刑事判決。法院在最高法院102年度台上字第2575號刑事判決（林國政案）與臺灣高等法院花蓮分院104年度上重更（一）字第1號刑事判決（蔡京京案）也有類似見解。

駁斥對被告有利的證詞，認為被告可能只是為了求生而造假討好監獄教誨師，判定被告「泯滅天良，惡性重大，罪無可逭，顯已非死刑以外之其他教育矯正刑所得導正教化」。

在臺灣高等法院106年度矚上重訴字第4號刑事判決（翁仁賢案）中，辯護律師提出一個曾在最高法院102年度台上字第170號刑事判決出現的抗辯：「被告已逾50歲，若執行無期徒刑，即使最快可以申請假釋的被告年齡，也是70幾歲快80歲了，被告出獄時已經年老，出獄後再犯機率低，判處被告無期徒刑就有預防再犯效果，是判處無期徒刑若和死刑有相同的預防功能。」但高等法院並沒有接受辯護人的論點，反而批評辯護人只考慮刑罰的特別預防功能，忽視刑罰的犯罪應報及一般預防功能，讓50歲以上之殺人犯在法律上擁有更多的特權與待遇，違反正義。值得注意的是，高等法院在這號判決裡用應報與一般預防讓教化可能性的解釋適用變得嚴格，而不是貫徹這個概念背後的特別預防理念。本案的教化可能性是不是最高法院102年度台上字第170號刑事判決裡所要求調查的教化可能性，已有疑問。

（3）走向後教化可能性時代？

在最高法院102年度台上字第170號刑事判決做出後的幾年，輿論對於教化可能性的批評越來越激烈。外界對於教化可能性的惡感似乎影響了最高法院，2016年之後最高法院對三個死刑定讞案件（鄭捷、李宏基與黃麟凱）的處理，更進一步地拆解了吳燦基準對於教化可能性的設定。高雄高分院更審李宏基案時，並沒有依照最高法院的要求進行調查⁵⁵。法院之所以沒將被告送鑑定，是因為李宏基本人拒絕被鑑定，也拒絕說明自己的想法，堅定表示會復仇，更一審法院改判李宏基死刑⁵⁶。或許為了合理化更一審的調查方式，

55 參見最高法院105年度台上字第480號刑事判決。

56 參見臺灣高等法院高雄分院105年度上重更（一）字第2號刑事判決。

最高法院刑事第九庭以「至於行為人有無教化可能，雖屬法院量刑時當予審酌之事項，但並非唯一，若所犯情節嚴重，自難因此解免死刑應報」的理由，免除了教化可能性的證明⁵⁷。在解決法理問題的同時，這個判決讓教化可能性的判斷在死刑量刑變得可有可無。

不過類似的挑戰早在鄭捷案就出現。雖然鄭案的下級審法院對鄭捷做了非常詳細的鑑定，鑑定結果也支持鄭捷的死刑判決⁵⁸，跟李宏基案的情況完全不一樣。但最高法院在最高法院105年度台上字第984號刑事判決裡，明確表示「教化」非死刑刑罰之目的，直接跳過了教化可能性如何調查這一題，創造了另一種死刑量刑基準。在2017年的黃麟凱案，由於更一審法院委任的專家在被告是否具有再社會化可能性的問題上，並未給予明確的答案，法院因而加入被告當初的犯罪手段、犯後態度與被害者的反應進行綜合判斷，對其中一個殺人行為判處無期徒刑，另一個強制性交殺人行為判處死刑⁵⁹，形成一個人可以同時被評價為有教化可能性與無教化可能性的矛盾，或是說教化可能性變成不是對於人的綜合判斷。面對被告的挑戰，最高法院在主張教化可能性只是眾多量刑因子的其中一個，可以與其他因子綜合判斷，駁回被告上訴，讓死刑定讞⁶⁰。雖然最高法院在黃麟凱案還維持著教化可能性這個量刑要素，但這個判決同樣顛覆了吳燦基準對於教化可能性的設定，教化可能性不再是被獨立出來調查與判斷的量刑因子。之所以會有這樣的發展，雖然不能忽視教化可能性之鑑定自身的困難與爭議，以及輿論的影響，但是當初建議教化可能性之吳燦基準並未提供清楚的操作細節，容許法院自行適用，對於後續的紛擾與歧異也有責任。

57 最高法院發回時，要求下級法院更審時釐清被告是否具有教化可能性，不能單純以被告審判時的言行進行判斷，參見最高法院105年度台上字第3424號刑事判決。

58 參見臺灣高等法院104年度囑上重訴字第6號刑事判決。

59 參見臺灣高等法院105年度軍上重更（一）字第2號刑事判決。

60 參見最高法院106年度台上字第810號刑事判決。

(三)「情節最重大之罪」所造成的混亂

「重視形式不重內涵，使得法院適用時標準不清」的問題，同樣出現在吳燦法官對於「情節最重大之罪」的處理上。在2013年年底，當吳燦法官有機會補充吳燦基準時，他將重點放在準備程序時曾提出，但卻未在最高法院102年度台上字第170號刑事判決明確處理的部份：何謂公民與政治權利國際公約第6條第2款「非犯情節最重大之罪」？由於聯合國人權事務委員會對於「情節最重大之罪」的解釋，只有「蓄意殺害並造成生命喪失」，這樣的標準可能會讓所有的故意殺人行為都可以判死刑，讓殺人罪從相對死刑變成唯一死刑。因此當最高法院開始適用兩公約處理死刑案件時，如何在各種故意殺人罪中選擇「情節最重大之罪」的議題便浮上檯面⁶¹，吳燦法官想要建立一個符合公政公約的量刑準則，的確不能忽略這一題。

在2013年年底的最高法院102年度台上字第5251號刑事判決裡，針對「情節最重大之罪」，吳燦法官主張在「在審判實務上，對於被告所犯罪名法定刑有死刑（相對死刑）之案件，則仍須回歸以被告具體個別犯罪情節、所犯之不法及責任之嚴重程度等犯罪情狀，得否作為選擇科處死刑之充足理由為斷。刑法第57條明定科刑時，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意該條所列10款事項，以為科刑輕重之標準，確立以罪責原則為量刑之基礎。」他的意思是，「情節最重大之罪」的判斷必須經過刑法第57條所規定的審查。至於調查的方式，一樣是對刑法第57條所例示之10款事由逐一檢視審酌。這號判決讓刑法第57條各款量刑因子的盤點有了國際人權公約的意義，這個見解也將刑法的規定與公約條款

61 最高法院曾經有「故意剝奪他人生命就是情節最重大之罪」的見解，參見最高法院102年度台上字第4486號刑事判決。學術討論參見廖福特（註14），頁918-928；王正嘉（註14），頁714-718；高涌誠、黃淑芳（註27），頁62-65；謝偉偉，論「教化可能性」（註14），頁145-146。

架接起來。

在2016年之最高法院105年度台上字第1567號刑事判決（吳敏誠案）裡，吳燦法官不僅再度強調上述觀點，又進一步指出「所犯即使是『情節最重大之罪』，亦僅係得以選擇死刑之『必要條件』，而非『充分條件』」。意思是法院若要判死，除了認定被告犯下情節最重大之罪之外，還必須判斷被告的教化可能性。這個見解講的雖然是「情節最重大之罪」在量刑體系上的地位，但同時確認教化可能性的審查作為死刑量刑的另一個必要條件，明確地將死刑量刑分為兩個層次，或許是對於兩個月前最高法院105年度台上字第984號刑事判決（鄭捷案）明確排除「教化可能性」作為死刑量刑因素的一個回應。

平心而論，雖然最高法院102年度台上字第5251號刑事判決所建議的審查方式沒有新意，但還是幫助最高法院過濾掉一些論證粗糙的判決⁶²，就死刑的科處做了比較好的把關。只是，當所有的法官都開始在可能判死的案件中使用刑法第57條進行審查時，最高法院102年度台上字第5251號刑事判決所建議的審查方式就「江郎才盡」了。最主要的原因是，吳燦基準所仰賴的刑法第57條只確定了罪責原則，並劃定了量刑應審酌的範圍，但就各個量刑事由可能涉及之情狀的價值判斷與衡量，這個條文並沒有給予具體的指示。到底在「蓄意殺害並造成生命喪失」之外，還需要什麼要件，才算是犯下「情節最重大之罪」，依然取決於個別法院的想法。令人費解的是，刑法第57條的規定對於死刑量刑指引有限一事，吳燦法官並不是沒有意識到。早在最高法院102年度台上字第170號刑事判決裡，他曾經對照學者論文對於外國立法例的歸納⁶³，指稱我國刑法

62 例如：最高法院103年度台上字第561號刑事判決（「……不能謂凡犯殺人罪者，則應處以死刑。原判決以上訴人係犯殺人罪，屬「情節最重大之罪」即予量處死刑，已有未合。……」）。

63 判決內引用的是賴宏信（註14）的研究。

第57條「並未提供可茲法院在此二者間選擇之具體標準」。當他有機會定義何為「情節最重大之罪」時，他還是只要求審判者審酌刑法第57條各款，並沒有在判決中提供可供參酌的抽象標準或具體實例。

2014年之後，絕大多數的最高法院判決參照最高法院102年度台上字第5251號刑事判決，以盤點刑法第57條的方式決定何為「情節最重大之罪」⁶⁴。這幾年下來，除了人權委員會已經明確主張的，預謀殺人才足以構成「情節最重大之罪」，因此間接故意或是非預謀殺人的行為都不該當，法院有比較一致的意見之外⁶⁵，多數法院還是「憑感覺」，有時會有輕重失衡的判斷。譬如在最高法院104年度台上字第2465號刑事判決裡，針對被告預謀殺人且預謀殺人後分屍的行為，最高法院認為在判斷被告是否犯下情節最重大之罪時，既然被告已經被判侵害屍體的罪名，就不能重複評價⁶⁶；但在最高法院106年度台上字第345號刑事判決裡，最高法院卻將手段較不駭人聽聞的棄屍方式納入「情節最重大之罪」的考量⁶⁷。

除了「情節最重大之罪」的判斷欠缺實質標準，導致法院的決

64 例如：最高法院103年度第561號刑事判決、最高法院105年度台上字第682號刑事判決、最高法院106年度台上字第345號刑事判決、最高法院107年度台上字第294號刑事判決。

65 譬如：最高法院103年度台上字第807號刑事判決（被告縱火臺南新營醫院北門分院附設護理之家，造成59人受傷、13人不幸身亡出於「殺人之不確定故意」，並非「蓄意殺害」）、最高法院105年度台上字第1559號刑事判決（被告偷竊公司財物，不滿被害人提告，於對質過程中憤而將她勒死，非預謀殺害）。

66 最高法院104年度台上字第2465號刑事判決（「至於被告殺害被害人後竟又肢解屍體、焚燒屍體、遺棄屍體，社會普遍觀感誠屬駭人聽聞、心狠手辣，與國人普遍社會情感有明顯重大背離，惟被告此部分已經另該當刑法第二百四十七條第一項之侵害屍體之罪名，自應於該罪名下予以評價，以避免再對被告殺人犯行進行雙重評價。」）

67 最高法院106年度台上字第345號刑事判決（「事後為圖滅跡，更以水泥封裝陳○軒屍體丟棄至桃園市觀音區台六十一線四十四公里處附近風力發電廠旁水池以沈屍，圖使陳○軒屍體永不被發現，渠等思慮縝密，手段殘暴，視他人生命如草芥，顯無尊重他人生命之概念……」）。

定可能矛盾或輕重失衡之外，最高法院102年度台上字第5251號刑事判決將刑法第57條與公政公約架接起來，反而讓刑法第57條的盤點目的變得混亂。原先在最高法院102年度台上字第170號刑事判決裡，盤點刑法第57條的目的在於讓法院看見「活生生的社會人」；但在最高法院102年度台上字第5251號刑事判決，盤點刑法第57條的目的在於決定被告是否犯下「情節最重大之罪」。除非所謂的「情節最重大之罪」講的就是一個包括對被告有利不利之整體評價的結果，如此才可能將被告還原為「活生生的社會人」的審查目的包括進去。參閱公民與政治權利公約的相關文獻，這個概念向來被用來排除那些不適當判死刑的犯罪，譬如：通姦罪、貪污罪、政治犯、叛亂罪、間諜罪、運送有毒物品罪、未造成死亡的擄人勒贖罪，或是未造成死亡的持槍械強盜罪等行為⁶⁸。從相關討論來看，公約著重行為本身的惡行，從這個角度對死刑之適用做第一個層次的把關。意思是，只要行為惡性不到重大的程度，根本不可對行為人施以死刑。既有的解釋並未說明，所謂「情節最重大之罪」的衡量有什麼限制，如果又加上了對於犯罪人做整體的盤點才下這個結論，是否誤會人權公約？

如果說人權公約與憲法一樣，都是人權保障的基本規定，「情節最重大之罪」的審查標準比公約嚴格，應該不會有違反公約的疑慮。在決定何為「情節最重大之罪」，因而決定特定的犯罪行為人是否應科處死刑，若能考量其個人因素，的確有可能讓「情節最重大之罪」的決定門檻提高，讓某些情有可原，或是犯後表現悔悟的犯罪者不會被認定犯下「情節最重大之罪」，不用等到教化可能性的判斷。不過，人的因素一旦放進來讓審判者一起綜合審酌，也有可能讓某些犯行嚴重程度中等，但被告犯後態度特別惡劣的案件，

68 參見廖福特（註14），頁921-923；林慈偉，論公民與政治權利國際公約生命權概念於我國刑事司法之實踐，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁64-67（2013年）。

或甚至是被害人家屬反應特別激烈的案件，變成「情節最重大之罪」，成了可以選科死刑的案件。因此，讓「情節最重大之罪」的決定綜合審酌刑法第57條所有的量刑事由，潛藏著死刑範圍擴張的風險，如此其實違反公政公約一開始想要透過這個概念限縮死刑適用範圍的目的。

回到一開始說的刑法第57條各款量刑事由盤點目的混亂一事，最高法院102年度台上字第5251號刑事判決就「情節最重大之罪」之判斷方式的規劃，很容易促使法院只重視犯行的動機、手段與所生的危險或傷害，使得原本最高法院102年度台上字第170號刑事判決想要讓法院在量刑時將被告當成是一個活生生的社會人的目的落空，那些跟犯罪行為人有關的考察，更像是個過場。刑法第57條的規定並不是跟「情節最重大之罪」的判斷無關，犯行的動機、手段與造成的危險與傷害當然都是重點，只是最高法院102年度台上字第5251號刑事判決對於本條的盤點並未做類型區分，也無審查層次的規劃，加上並未提供可供參酌的最嚴重犯罪的類型，使得本號判決所帶來的問題，比其能夠解決的事更多。

（四）小結

2013年年初，吳燦法官在「天時」（2010年臺灣社會爆發廢死風暴之後，政府重啟死刑執行，社會高度重視法院的量刑結果）、「地利」（最高法院面對改革壓力，決定在最高法院開啟死刑量刑辯論，量刑辯論的進行需要一套量刑準則可供依循）與「人和」（法院收到一個曾在一審被判無期徒刑，二審改判死刑的殺人案件。這種邊緣案件，特別適合發展一套量刑準則）的條件背景下，參酌當時司法實務已有的一些作法，加上自己對於量刑該怎樣做成的設想，作出最高法院102年度台上字第170號刑事判決。從該判決要求法院必須遵守各項法理原則，設計特定的量刑調查方式，希望法院從活生生的社會人的角度來量刑，以及透過客觀調查確認死刑是否不得

不然的角度來看，這個判決確實用心地為現階段仍無法廢死的臺灣提供一個死刑量刑基準，期待死刑的量刑能有深度，標準不再恣意。

從結果來看，2013年之後，死刑量刑的說理密度的確提高了，再也看不到法院用傳統簡短方式合理化死刑的決定。甚至從數字來看，與2008年至2012年相比，2013年到2017年的死刑定讞數量明顯下降，若對比這幾年的犯罪率，數字的下降與最高法院開始建立死刑量刑準則有關⁶⁹。只是深入分析相關判決，可看到法院是否判死，相當程度仍取決於法院用什麼態度進行審查，找誰來進行教化可能性的實證調查。再加上最高法院102年度台上字第170號刑事判決對其他法院並無法的拘束力，以至於當社會大眾對於特定重大犯罪行為有相當大的情緒反彈，或是該犯行屬於法官自身無法接受的情況時，有些法院會用綜合考量刑罰目的的方式，或是降低教化可能性的獨特性，扭轉吳燦基準的適用方式。或是自創新的量刑基準，以回應大眾對於司法正義的期待。過去這幾年，因而出現死刑量刑的說理密度提高，甚至論證的嚴謹度增加，但死刑量刑依然標準不一致，因而法院判生判死的決定仍然顯得恣意任性的奇特現象。

臺灣這幾年關於死刑量刑基準的實驗，似乎走到了一個關卡，有必要重新思索，究竟是要補足吳燦基準沒有講清楚的細節，還是要另創量刑基準？建立死刑量刑基準，究竟只是司法的事，還是立法者也有責任？

⁶⁹ 從2013年到2017年為止，一共有7個死刑判決定讞。2008年到2012年共有43個死刑判決定讞，與2013年到2017年有六倍之差。若對比2008年到2017年的故意殺人案件發生數（並無六倍之差），2013年開始發展與適用的死刑量刑模式，對死刑定讞的人數的確造成影響。參見：司法院，13. 最高法院刑事上訴案件被告裁判結果——按年別分，司法統計年報2017年，<https://www.judicial.gov.tw/juds/>（最後瀏覽日：2018年7月26日）；警政署，故意殺人統計，<https://ba.npa.gov.tw/npa/stmain.jsp?sys=100>（最後瀏覽日：2018年7月26日）。

參、借鏡美國模範刑法典

相對於臺灣在近幾年才開始思考死刑量刑基準的問題，美國在1972年就開始進行死刑量刑程序的改革。那一年，美國聯邦最高法院做出*Furman v. Georgia*案判決，宣告該案適用的死刑條文違憲⁷⁰。*Furman*案判決相當程度讓所有仍保有死刑制度的州（以下簡稱死刑州），其死刑量刑程序都有被宣告違憲的危機。為了維持死刑制度的運作，美國死刑州開始進行死刑量刑程序的改革。美國法律協會在1962年擬定的模範刑法典，其中關於死刑的量刑程序，在這個背景下受到重視。由於1976年的*Gregg v. Georgia*一案，確認了仿照模範刑法典的量刑模式符合美國聯邦憲法的規定⁷¹，美國保留死刑的地區隨後都模仿了模範刑法典的做法。自此之後，美國死刑量刑制度的發展，就是在模範刑法典的模式上進行修正。因此，要了解美國的死刑量刑模式，必須從美國法律協會的模範刑法典開始。

一、美國模範刑法典之死刑量刑模式

擬定模範刑法典的美國法律協會是個民間學術組織，由司法實務工作者與學者組成，目的在促成美國法的現代化。就刑法的問題，鑒於各州刑法經過多年之後呈現相當程度的混亂與不理性，註釋彙編不足以處理刑法領域的問題，美國法律協會因此在1950年代末期決定擬訂一套模範刑法典，於1962年會員大會通過之後對外公布定案⁷²。

模範刑法典中關於死刑量刑程序之規定，被放在第210條《刑事殺人罪》（*criminal homicide*）底下。該條先規定了殺人罪

⁷⁰ See *Furman v. Georgia*, 408 U.S. 238 (1972).

⁷¹ See *Gregg v. Georgia*, 428 U.S. 153 (1976).

⁷² Carol S. Steiker & Jordan M. Steiker, *No More Tinkering: The American Law Institute and the Death Penalty Provisions of the Model Penal Code*, 89 TEX. L. REV. 353, 355 (2010).

(murder)等3種刑事殺人行為，以及加工自殺罪的犯罪構成要件，在第210.6條規範在何種情況下可對殺人罪判處死刑，以及決定死刑的程序。至於第210.6條本身有4項，第1項是死刑量處的一般性規定，第2項規定死刑量刑的進程序，第3項列舉死刑量刑的從重量刑情狀 (aggravating circumstances)，第4項例示死刑的從輕量刑情狀 (mitigating circumstances)。對於外界而言，所謂模範刑法典之死刑量刑模式，指的是「從重量刑與從輕量刑情狀模式」。

(一) 可判處死刑的一般性規定

本條第1項反面規定何種情況可以量處死刑。依據該項之規定，殺人罪若具備以下6種情況其中之一，審判者僅能判處一級重罪的刑度⁷³：(a)於現在或未來依據本條第2項進行的審判程序中，並無證據可證明存有本條第3項所列舉的從重量刑情狀；(b)審判中有證據可證明本案具備可請求寬貸之具有相當份量的從輕量刑情狀；(c)在檢察官的同意與法院的核可下，被告對一級重罪的殺人罪認罪；(d)被告於犯罪時在18歲以下；(e)被告之身體或心智狀況可請求寬貸；(f)即便證據已足夠定罪，仍未排除對於被告罪行是否成立的疑問。

鑑於整部模範刑法典只有第210條《刑事殺人罪》有死刑的規定，條文中又進一步限制在殺人罪上，因此只有殺人罪的被告才有判處死刑的資格。但審判者若真的要判處被告死刑，該殺人行為還必須依據本條第2項的程序，進一步確認是否具備本條第3項所列舉的從重量刑情狀，並且不具備不限第4項之可請求寬貸具有相當份量的從輕量刑情狀。剩下的4款規定，則是要求審判者不得對與檢察官就一級殺人罪進行認罪協商的被告、18歲以下的被告、身體或心智狀況可請求寬貸的被告，以及罪行仍有殘存疑問的被告判處死

⁷³ 依據模範刑法典第6.06(1)條之規定，「一級重罪之刑度應由法院決定，最低刑度在1到10年之間，最高刑度為無期徒刑。」

刑。

（二）死刑量刑的程序

由於模範刑法典意在提供美國仍維持死刑制度的州與聯邦參考，本條第2項之死刑量刑程序就規劃了由法院單獨決定，或是由法院與陪審團共同決定等可能的作法。這兩種程序的共通性包括：（1）定罪與量刑程序分離；（2）在量刑程序中，任何法院認為與量刑有關之事項的證據均可被提出，包括（但不限於）犯罪的本質與情狀、被告的人格、背景、歷史、心智與身體狀況，以及任何本條第3項與第4項列舉的從重量刑與從輕量刑情狀；（3）任何法院認為有證明價值的證據都可以提出，不論依據證據排除法則其證據能力為何。只要該證據不涉及法律特權，也只要被告律師有適當機會反駁上述證據，檢察官以及被告或其辯護人應被允許提出論證，以支持或是反對對於被告判處死刑；以及（4）除非審判者認定存在任一本條第3項所列舉的從重量刑情狀，並進一步地認定並不存在其他具有相當份量、足以請求寬貸的從輕量刑情狀，不應判處或建議死刑。

其他比較重要的程序包括：在陪審團參與的程序裡，法院應告知陪審團倘若建議法院判處被告徒刑，該徒刑的性質，以及被告有可能被假釋。在法院單獨決定的程序裡，法院應依據模範刑法典第7.07條審酌量刑前的調查報告。倘若被告曾被送精神鑑定，法院應考量此精神鑑定報告。

（三）死刑案件必備的從重量刑情狀

依照本條第1項與第2項的規定，被告除了犯下殺人罪之外，其犯罪情狀還必須至少滿足本條第3項列舉之從重量刑情狀的其中一種，才能夠被判處死刑。換言之，本條第3項從重量刑情狀，是一個案件能被判處死刑的必要要件。

本項前7款為具體的犯情描述，(h)款則是採取評價性的抽象規定，設計此規定的人顯然擔心列舉規定有掛一漏萬的問題：(a)該殺人行為乃是被告於受到徒刑執行時犯下的；(b)被告曾有殺人前科，或是曾犯下涉及使用或威脅對他人使用暴力的重罪；(c)在被告犯下殺人罪時，同時犯下其他殺人罪；(d)被告故意製造多人的死亡風險；(e)殺人行為是在被告犯下搶劫、強制性交，強制或脅迫肛交口交、縱火、入侵住宅竊盜或是綁架時所為，或為共犯、試圖犯下或於逃亡之後犯下上述罪名時所犯；(f)殺人行為乃是為了逃避或是避免被合法逮捕，或是試圖從一個合法拘禁中逃亡時所犯下；(g)殺人行為是為了獲得金錢利益；(h)殺人行為特別殘暴（heinous）、窮凶惡極（atrocious）或殘忍（cruel），顯示被告異常的墮落腐敗（depravity）。

（四）可能調整刑度的從輕量刑情狀

依照本條第1項與第2項的規定，即便被告之犯行具有從重量刑情狀，但若存在相當份量、足以請求寬貸的從輕量刑情狀，審判者仍不應判處被告死刑。意思是，如果從重量刑情狀是死刑判決的正向因素，那麼本條第4項從輕量刑的情狀就是死刑判決的負向因素。

本項與第3項一樣有8款，涵蓋被告之前科、精神與心智狀況、動機或是人格成熟度：(a)被告並無重大的犯罪歷史；(b)殺人行為是在被告受到極端精神或是情緒障礙的影響所犯；(c)被害人參與被告的殺人行為，或同意此一殺人行為；(d)殺人行為乃是在被告自認具有道德正當性，或是自信可以被從輕量刑時的情況所犯下；(e)被告乃是他人殺人行為之共犯，但其對於殺人行為的參與相對不重要；(f)被告的行為受到脅迫或他人的支配；(g)在殺人的時候，被告理解其犯行之錯誤的能力，或是依法律行事的能力，受到精神疾病、心智缺陷或是酒醉的影響；(h)被告犯罪時年紀尚輕。

不過必須注意的是，依照本條第2項的規定，審判者於量刑可

以考量的從輕量刑情狀並不限於本項之規定，因此第4項的從輕量刑情狀只是例示。不過即便如此，鑑於某些因子也有可能被當作死刑量刑的正面因子，譬如被告受到酒精的影響，也有可能被檢方當作是被告欠缺自制力，對社會存在相當大的危險，要求審判者處被告死刑，本項規定仍有「限定審判者將此8款情狀當作死刑量刑的負向因素」的意義。

二、模範刑法典的影響

(一) 模範刑法典的時代意義

在模範刑法典提出的時候，美國可判處死刑的犯罪類型遠不止殺人罪，法律與最高法院判決也未限制審判者對於未成年人、身體與心智狀況有問題的人量處死刑。死刑案件的定罪與量刑並沒有被分開來，因而陪審團在量處被告死刑時，對於被告常常所知有限⁷⁴。更重要的是，美國當時主流的刑罰理念支持矯治復歸主義，尊重法官對於刑的裁量，欠缺上訴審查標準⁷⁵。這個特徵也反映在死刑量刑上，即便涉及人的生死，法律並未給予審判者任何的標準或指引，審判者擁有不受約束的裁量權⁷⁶。

因此對比同時代的美國法，模範刑法典對於死刑的規定超前於它的時代⁷⁷。但從國家濫權，黑人通常為最大的受害者，自由派以

74 CAROL S. STEIKER & JORDAN M. STEIKER, *COURTING DEATH: THE SUPREME COURT AND CAPITAL PUNISHMENT* 44-45 (2016).

75 Michael Tonry, *Sentencing in America, 1975-2025*, 42 CRIME & JUST. 141, 141-42 (2013).

76 Steiker & Steiker, *supra* note 72, at 356-57. 不過即便當時審判者擁有不受限制的刑罰裁量權，大體而言，在1930年代到1975年這段期間，美國的刑罰並不嚴厲，美國是在1980年代之後進入嚴刑峻法時代。See Tonry, *supra* note 75, at 142.

77 關於死刑，模範刑法典本來可以更超前於它的時代。在法典草擬當時，美國的廢死運動逐漸興盛，因而在法典草擬過程中，曾有諮詢委員建議廢除死刑、不在模範刑法典裡將死刑納入可能的刑罰種類。然而這樣的提議並未被美國法律協會的理事會接受，美國法律協會理事會認為該協會不應採在死刑存廢的議題上取任何立場。鑑於美國仍有地區維持死刑制度，美國法律協會改為在模範刑法

及少數族裔的法律人早就有以革新刑事程序的方式，減少刑事司法程序中的種族歧視之改革傾向的角度來看，模範刑法典對於死刑的規範方式呼應了美國當時的氛圍，這其實是美國聯邦最高法院介入州死刑制度改革的重要背景⁷⁸。不過，模範刑法典於1962年通過之後，雖然其他部分的規定很快地成為美國各州刑法修法的參考對象，其死刑量刑的規定並未受到太多的重視，至多6個州仿照採取定罪與量刑分離的程序⁷⁹。一直要到1972年，美國聯邦最高法院在 *Furman v. Georgia* 一案宣告喬治亞州的死刑條文違憲，模範刑法典中的死刑量刑規定才開始產生影響力。

（二）*Furman*案與*Gregg*案的催化

*Furman v. Georgia*案其實是一個高爭議性的5比4判決，五個大法官還各有意見，有共識的只有本案死刑量刑程序違反憲法增修條文第8條。在主張喬治亞州死刑量刑程序違憲之大法官之中，William J. Brennan Jr.與Thurgood Marshall大法官認為所有的死刑都違憲，William O. Douglas、Potter Stewart與Byron White三位大法官並不同意死刑本質上違憲，但認為本案的死刑量處程序恣意、任性與歧視，有讓少數族裔特別容易被判處死刑的問題。*Furman*案判

典中制定與死刑量刑有關的條文，提供依然保有死刑的州或聯邦作為參考。參閱模範刑法典第210條的立法註釋（§ 210 explanatory note）。至於美國當時廢死運動的狀況，參考王玉葉，美國最高法院審理死刑合憲性原則——試看 *Furman*、*Gregg* 與 *Atkins* 三案之軌跡，收於：歐美死刑論述，頁94-98（2010年）。

⁷⁸ 學者指出，1950年代到1960年代的民權運動促使美國聯邦最高法院重視種族問題，開始積極透過憲法審查的方式，處理各州刑事司法制度的種族偏見。不過這也跟美國有色人總權益促進協會（NAACP）下的法律辯護基金（Legal Defense Fund, LDF）的策略有關。嚴格來說，當時的死刑判決數量其實不多，但死刑卻不成比例地用在犯下強制性交的黑人被告身上，死刑量刑程序充滿恣意。LDF因此積極透過訴訟案件挑戰美國死刑制度，以降低司法中之種族問題對於黑人的負面影響。See STEIKER & STEIKER, *supra* note 74, at 40-60.

⁷⁹ See *id.* at 357 n.29.

決讓全美的死刑條文陷入違憲的危機，也引起相當大的反彈⁸⁰。由於*Furman*案中5票中只有2票認為死刑本質違憲，3票暗示如果死刑量刑程序更有結構，讓死刑公平地執行，死刑有可能恢復，美國仍保有死刑的州便開始著手修改死刑條文⁸¹。

*Furman*案後至少有35個州重新修訂死刑量刑的法律⁸²，修法取向大致分為兩派，一派制定絕對死刑制度（mandatory death penalty），以解決裁量權恣意的問題；一派仿效模範刑法典的規定，這兩種做法很快就被送到美國聯邦最高法院。結果是，絕對死刑制度被美國聯邦最高法院宣告違憲⁸³，採取模範刑法典的規定被美國聯邦最高法院宣告合憲。美國聯邦最高法院在*Gregg v. Georgia*案判決中以美國法律協會的模範刑法典為例，反駁前一年*McGautha v. California*一案⁸⁴中「創立量刑準則，指引陪審團審酌量刑是不可能的」的說法⁸⁵；在*Proffitt v. Florida*一案中，注意到佛州的法條乃是仿效模範刑法典⁸⁶；在*Jurek v. Texas*一案中，指出德州試圖在法條中限縮可處殺人罪的類型，與模範刑法典之從重量刑情狀的目的之一致⁸⁷。這三個判決一出，其他還沒有參考模範刑法典修改死刑量刑規定的州紛紛轉向，美國法律協會的模範刑法典自此

80 王玉葉（註77），頁106-107。

81 *Furman*, 408 U.S. at 240-374.

82 BARRY LATZER, DEATH PENALTY CASES: LEADING U.S. SUPREME COURT CASES ON CAPITAL PUNISHMENT 47 (2d ed. 2002).

83 See *Roberts v. Louisiana*, 428 U.S. 325 (1976); *Woodson v. North Carolina*, 428 U.S. 280 (1976). 美國聯邦最高法院以（1）強制性的刑罰規定長久以來被認為過度嚴厲與無法運作、（2）強制性的刑罰無法約束審判者的權力，只是把恣意的問題提早到定罪階段而已、（3）唯一死刑的規定讓審判者無法考量被告之性格與背景，宣告唯一死刑制度違憲。See LINDA E. CARTER, ELLEN KREITZBER & SCOTT HOWE, UNDERSTANDING CAPITAL PUNISHMENT LAW 70 (3d ed. 2012).

84 *McGautha v. California*, 402 U.S. 183, 204 (1971).

85 *Gregg*, 428 U.S. at 193-95.

86 *Proffitt v. Florida*, 428 U.S. 242, 247-48 (1976).

87 *Jurek*, 428 U.S. at 270.

成為美國各州修改死刑量刑程序所參照的版型（template）⁸⁸。

值得注意的是，美國聯邦最高法院雖將*Gregg*、*Proffitt*與*Jurek*等案合併審判，宣告這三個案件所涉及的死刑量刑程序合憲，但這三個州的死刑量刑程序並不完全相同，從重與從輕量刑因子的安排也存在差異。不過依照美國聯邦最高法院在*Gregg*案對於*Furman*案意旨的摘要——「為了極小化死刑施行在恣意選定的罪犯上的風險，量處死刑的決定必須受到某些準則的引導（guided by standards），可使具有量刑權力的審判者可以聚焦在犯罪與被告的特定情狀（the particularized circumstances of the crime and the defendant）⁸⁹」，三州間的程序差異被認為不重要，只要這死刑規定能夠讓（1）審判者的裁量權受到指導（guided discretion），以及（2）死刑的裁量能夠個別化（individualized）即可。至於如何達到上述這兩個目的，美國聯邦最高法院開放各州自行設計。美國聯邦最高法院在*Gregg*案的意見，給了各州自行發展死刑量刑制度的空間⁹⁰。

三、美國聯邦最高法院對於死刑機器的調整

*Gregg*案判決不僅確立了美國死刑量刑方式的立法走向，也確立了美國聯邦最高法院在美國死刑制度的發展上的主導角色。從那時候開始，美國死刑制度就在美國聯邦最高法院的帶領下，走向透過司法判決調整校準死刑機器的道路⁹¹。調整的準則除了憲法已有的規定（譬如被告受律師協助的權利）之外，*Gregg*案中確立的兩個原則：（1）審判者的裁量權是否受到指導，以及（2）死刑的裁量是否能夠個別化是重點。

⁸⁸ Steiker & Steiker, *supra* note 72, at 355.

⁸⁹ *Gregg*, 428 U.S. at 199.

⁹⁰ 關於各州死刑量刑程序之差異，參見CARTER, KREITZBER & HOWE, *supra* note 83, at 64-73.

⁹¹ See STEIKER & STEIKER, *supra* note 74, at 8-9, 17-26, 40.

針對從重量刑情狀與從輕量刑情狀，例如在1976年的*Jurek v. Texas*一案中⁹²，美國聯邦最高法院同意將未來危險性作為陪審團決定是否量處死刑的因素之一，即便被告爭執未來的行為無法被預測。在1978年之*Lockett v. Ohio*一案中⁹³，美國聯邦最高法院認為俄亥俄州的死刑條文之從輕量刑情狀的清單過窄，不能讓審判者充分地考量案件與被告的背景，因此違憲。在1980年的*Godfrey v. Georgia*一案中⁹⁴，美國聯邦最高法院認為喬治亞州對於死刑從重量刑情狀的規定（殺人行為是「令人髮指或是放肆地邪惡、可怖或是無人道的，涉及凌虐、腐化的心、或是對於被害人加重情狀的毆打行為」）並非本質違憲，而是法院未對陪審團給予適當的指示，使得該法條在本案的適用過於模糊而違憲。在1991年*Payne v. Tennessee*案中⁹⁵，以陪審團有權聽取所有與被告犯行所製造之傷害有關的證據，支持被害者影響陳述（victim impact statement）作為為加重量刑的證據。

在死刑量刑程序上，例如在1984年之*Spaziano v. Florida*一案裡⁹⁶，美國聯邦最高法院支持佛羅里達州之規定，允許法官可以推翻陪審團之無期徒刑的建議，改判死刑，理由是這樣的設計並未讓死刑的量處不理性或是恣意。在1990年的*McKoy v. North Carolina*一案裡⁹⁷，美國聯邦最高法院認為北卡羅萊納州要求陪審團必須在從輕量刑情狀上一致決的規定，不當地限制陪審團考量從輕量刑因素，因而違憲，即便法律要求陪審團必須在從重量刑因素上採取一致決。至於模範刑法典採取之定罪與量刑程序分離制度，美國聯邦

92 *Jurek*, 428 U.S. at 274-76.

93 *See Lockett v. Ohio*, 438 U.S. 586 (1978).

94 *See Godfrey v. Georgia*, 446 U.S. 420 (1980).

95 *See Payne v. Tennessee*, 501 U.S. 808 (1991).

96 *See Spaziano v. Florida*, 468 U.S. 447 (1984).

97 *See McKoy v. North Carolina*, 494 U.S. 433 (1990).

最高法院從未明確地要求各州採取此一程序⁹⁸。由於後來各州都仿效模範刑法典的做法，這件議題從未送到美國聯邦最高法院的面前。

從1976年到現在，美國聯邦最高法院對於死刑機器的調整校準當然不只有上述這些案件。有些議題曾經出現在模範刑法典第210.6條裡，譬如在1986年的*Ford v. Wainwright*一案中⁹⁹，美國聯邦最高法院認為美國憲法增修條文第8條禁止對一個精神失常的人執行死刑。有些算是對於從重與從輕量型模式的程序精進，譬如在1987年的*Burger v. Kemp*案中，美國聯邦最高法院以5比4的判決，認定律師的調查若未提供任何從輕量刑情狀的證據，不算是剝奪被告受律師有效協助的權利¹⁰⁰。在1990年*Walton v. Arizona*一案¹⁰¹，美國聯邦最高法院以5比4的判決，核可亞利桑那州要求被告擔負從輕量刑情狀壓過從重量刑情狀的證明責任，即便這樣的設計將判處死刑當作預設。有些則是基於美國聯邦憲法的其他條款，譬如在1986年*Lockhart v. McCree*¹⁰²，美國聯邦最高法院認為，倘若候選陪審員表達她對於死刑的反對會影響到她在死刑量刑的表現，就可以附理由地拒卻。1987年的*McCleskey v. Kemp*一案¹⁰³，算是*Furman*一案後對美國死刑制度最全面的攻擊。被告引用統計數據，主張喬治亞州的死刑制度存在種族歧視，侵害他美國聯邦憲法修正條款第14條正當法律程序的憲法權利，但美國聯邦最高法院多數意見並未接受此一觀點。

98 美國聯邦最高法院曾經在1971年的*Crampton v. Ohio*, 402 U.S. 183 (1971) 一案中，認為俄亥俄州使用定罪與量刑不區分的程序並不違憲。在*Gregg*一案中，美國聯邦最高法院指出，一般而言，*Furman*案所提出的問題，在定罪量刑區分的程序中最能被處理，但是法院並不願斷言這樣的程序必然可以滿足憲法要求，或是不採這樣的程序就一定不能滿足憲法的要求。*Gregg*, 428 U.S. at 195.

99 See *Ford v. Wainwright*, 477 U.S. 399 (1986).

100 See *Burger v. Kemp*, 483 U.S. 776 (1987).

101 See *Walton v. Arizona*, 497 U.S. 639 (1990).

102 See *Lockhart v. McCree*, 476 U.S. 162 (1986).

103 See *McCleskey v. Kemp*, 481 U.S. 279 (1987).

四、典範的撤銷

(一) 1980~90年代：死刑制度的擴張

美國20世紀的後四分之一世紀，死刑執行的數量大幅增加¹⁰⁴，數量直逼1950年代初期。之所以有這樣的結果，固然與當時的刑事政策越來越嚴刑峻法有關¹⁰⁵，但模範刑法典與美國聯邦最高法院的角色也不容忽視。

當初沒打算在死刑議題上積極帶領時代，只希望務實地給予還有死刑的州參考的模範刑法典，在美國聯邦最高法院的支持下，在1976年之後成為美國死刑制度的智識基礎。不過美國死刑制度的發展，關鍵點還是美國聯邦最高法院的態度，或是說美國聯邦最高法院對這套模式調整校準的方式。在1980年代末期，美國聯邦最高法院連續駁回幾個對於死刑制度的重要挑戰，包括是否可對未成年人執行死刑¹⁰⁶，對於心智障礙者判處與執行¹⁰⁷，以及死刑制度充斥種族偏見的問題¹⁰⁸。1990年代初期，美國聯邦最高法院反對被告使用可證明無辜的新證據聲請聯邦的人身保護令¹⁰⁹。於1990年代時，死刑判決（平均一年325個）與執行數量（全國將近一年100個）都相當高。於1990年代，有三個州重新恢復死刑（紐約州、堪薩斯、新罕布夏州），不少州致力於擴張死刑的利用。因為奧克拉市聯邦大樓爆炸案，國會限縮死刑判決之人身保護令的審查聲請¹¹⁰。

104 *Numbers of Executions Since 1976*, THE DEATH PENALTY INFORMATION CENTER, <https://deathpenaltyinfo.org/executions-year> (last visited Aug. 23, 2018).

105 Torny, *supra* note 75, at 144-45.

106 *See Stanford v. Kentucky*, 492 U.S. 361 (1989).

107 *See Penry v. Lynaugh*, 492 U.S. 302 (1989).

108 *See McCleskey v. Kemp*, 481 U.S. 279 (1987).

109 *See Herrera v. Collins*, 506 U.S. 390 (1993).

110 Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Pub. L. No. 104-132, §§ 101-08, 110 Stat. 1214, 1217-26 (codified as amended in scattered sections of 28 U.S.C.).

另一方面，由於所有的州都仿照模範刑法典修改死刑條文，採用從重量刑模式與從輕量刑模式，1980年代末期至1990年初期，美國出現「從輕量刑因子專家」，死刑辯護團隊大大擴展，有越來越多的專家投入死刑辯護，此一領域的法律也越來越精緻複雜¹¹¹。此外，死囚在定罪之後，可以請律師以其憲法權利受到侵害為由，提起上訴，向法院申請人身保護令，也使得死刑執行的時間相對拖延，這些情況導致死刑案件的訴訟越來越昂貴與耗時¹¹²。然而，即便耗費如此多精神與金錢，卻無法避免冤案的問題。在1980年代後期，開始有學者注意到死刑的誤判問題。自1999年至2003年，有35死囚被發現誤判而獲釋。根據美國死刑資訊中心調查統計，在1976年至2000年之間，美國共處決642名死刑犯，在此期間，卻有87位死囚在行刑之前被發現無辜¹¹³。死刑訴訟昂貴耗時，卻無法避免冤案的問題，加上一直有研究證明死刑存在種族歧視的問題，侵蝕大眾對於死刑制度的信心與支持¹¹⁴。

（二）21世紀：死刑風向的轉變

昂貴耗時，卻依然無法避免冤案與種族歧視的問題，在21世紀之後，成為美國死刑制度越來越沈重的包袱。面對這個問題，有些州（例如伊利諾州）宣布暫停死刑的執行，有些州（例如紐澤西、新墨西哥）乾脆將死刑廢除。北卡羅來納州制定特別條文對抗死刑制度中的種族偏見，有些州（譬如麻州）設置特別委員會研究死刑制度的問題¹¹⁵。在21世紀之後，美國聯邦最高法院開始讓死刑制度受到更多的挑戰，譬如在 *Wiggins v. Smith* 案，認為律師若未適當地

¹¹¹ STEIKER & STEIKER, *supra* note 74, at 196.

¹¹² 王玉葉，死刑是否殘酷的刑罰——美國最高法院解釋的演進，收於：歐美死刑論述，頁207-08（2010年）。

¹¹³ 王玉葉，美國聯邦主義與民意對美國廢止死刑之影響，收於：歐美死刑論述，頁83（2010年）。

¹¹⁴ STEIKER & STEIKER, *supra* note 74, at 195-210.

¹¹⁵ Steiker & Steiker, *supra* note 72, at 362-63.

去調查從輕量刑因素，將會構成無效的律師協助¹¹⁶；以及在 *Rompilla v. Beard* 案裡，要求死刑案件的律師盡適當的努力，獲取並審查那些有可能被檢察官拿來當作從重量刑情狀的證據¹¹⁷；在 *Roper v. Simmons* 案與 *Atkins v. Virginia* 案限制對於未成年人與心智障礙者執行死刑¹¹⁸；在 *Kennedy v. Louisiana* 案阻止將兒童性侵害但並未造成死亡，或並未故意造成死亡的行為處以死刑¹¹⁹。不過在2008年 *Baze v. Rees* 一案中¹²⁰，美國聯邦最高法院並未支持「死刑注射製造不必要的痛苦，因而違反美國聯邦憲法增修條文第8條禁止殘忍與不尋常的刑罰」的主張，核可了肯塔基州的雞尾酒注射法，避免美國的死刑制度受到根本的挑戰。

（三）美國法律協會撤銷模範刑法典中的死刑條文

在這樣的社會氛圍裡，美國法律協會的會員尤其關心美國死刑制度的問題，畢竟在1972年州的死刑制度面臨違憲問題時，是模範刑法典提供範例，幫助各州建立一套合憲的體制。2007年美國法律協會委託Carol Steiker（哈佛法學院）與Jordan Steiker（德州法學院）兩位教授研究美國死刑制度的相關問題，追問維持一個公平合理的死刑制度是否可能。美國法律協會想知道，協會究竟應該修改模範刑法典內的死刑條文，或是公開宣告支持廢除死刑，還是撤銷模範刑法典中的死刑條文¹²¹？

116 See *Wiggins v. Smith*, 539 U.S. 510 (2003).

117 See *Rompilla v. Beard*, 545 U.S. 374 (2005).

118 See *Roper v. Simmons*, 543 U.S. 551 (2005). *Atkins v. Virginia*, 536 U.S. 304 (2002).

119 See *Kennedy v. Louisiana*, 554 U.S. 407 (2008).

120 See *Baze v. Rees*, 553 U.S. 35 (2008). 死刑注射是否違憲的問題，讓全美死刑從2007年9月暫停至2008年4月。See Adam Liptak, *Challenges Remain for Lethal Injection*, N.Y. TIMES (Apr. 17, 2008), <http://www.nytimes.com/2008/04/17/washington/17lethal.html>.

121 Steiker & Steiker, *supra* note 72, at 367.

兩位Steiker教授其後提交一份報告（以下簡稱Steiker報告），從好幾個面向分析美國死刑制度的問題。報告首先指出，美國聯邦法院對於死刑制度的規範雖然讓死刑量刑程序較為嚴謹，但也是問題的一部份。譬如美國聯邦最高法院在*Gregg*案發展出的兩個量刑指導法則——讓審判者的裁量權受到指導，以及死刑的裁量能夠個別化，彼此間其實存在緊張關係。若陪審團可不受限制的考量從輕量刑事由，希望量刑可受指導與規範的期待就會被架空。撇開兩個原則之間的緊張關係，最高法院一開始介入死刑量刑，是希望避免量刑恣意與歧視，但是，面對各州建立死刑制度依然存在種族歧視時，美國聯邦最高法院卻無法提出適當的法則解決，甚至為此類挑戰設下相當高的門檻¹²²。對於大眾最在意的冤案問題，美國聯邦最高法院要求被告先向州法院要求救濟，只有在滿足相當高的證據門檻，才能向聯邦法院提出人身保護令的要求¹²³。對於死刑案件被告至關重要的律師協助，美國聯邦最高法院不是對於被告之「無效律師協助」的主張設下頗高的門檻，就是對於定罪之後上訴的律師協助毫無審查標準。只有到2000年之後，才轉而督促死刑案件律師協助被告調查從輕量刑事由¹²⁴。糟糕的是，由於美國聯邦最高法院頻繁介入死刑制度的運作，給了大眾「死刑案件受到司法嚴密監督」的錯誤印象，因此阻礙了其他部門對死刑制度進行大幅度的改革¹²⁵。

Steiker報告認為，*Gregg*案之後仿照模範刑法典所設定的死刑量刑準則，並沒有解決當初*Furman*案判決所意圖解決的問題。不少統計資料顯示，當被害人是白人時，被告被求處死刑的比例明顯高於其他。Steiker報告指出，種族歧視的問題之所以繼續糾纏美國

¹²² *Id.* at 380-84.

¹²³ *Id.* at 384-85.

¹²⁴ *Id.* at 385-88.

¹²⁵ *Id.* at 376-77.

死刑制度，是因為本該限縮死刑適用範圍的從重量刑情狀，範圍常常能夠涵蓋大部分的殺人行為，使得檢察官求刑與陪審團量刑的裁量恣意範圍擴大，報告批評模範刑法典本身的規定方式就有問題。此外，雖然有某些州修法准許被告使用統計資料作為種族歧視的證據，意圖處理*McCleskey*案的問題，然而被告還是得證明自己的案子存在種族歧視。因而這樣的立法不但對於個案沒有幫助，反而會製造一種錯覺：當法律已經提供種族歧視的救濟管道，卻沒有半個案件可以成立，表示死刑制度並不存在種族歧視¹²⁶。

至於*Gregg*案之後的死刑量刑程序改革是否能夠幫助陪審員，做出一個具有論證基礎的道德決定，避免衝動、恣意或歧視，*Steiker*報告引述實證研究，指出現實與理想的差距。例如：即便定罪程序與量刑程序分開，陪審員有在定罪階段就決定是否判死刑的傾向；陪審員做決定時不是不能理解從輕量刑情狀的意思，就是不重視從輕量刑情狀的證據。實證研究顯示死刑量刑改革並未減少*Furman*案之前存在之死刑量刑的恣意性，有部分是因為美國聯邦最高法院對於何謂受到指導的裁量權要求並不多，只要各州能夠限縮能判死刑的範圍就好；有時是個案中法官的指示過於複雜，陪審團不能正確理解；有時問題在於法律本身的規定，譬如：法律若不禁止陪審員考量非法定的從重量刑事由，那麼陪審員在量刑時，其考量容易漫無邊際。要求陪審員衡量從重量刑情狀與從輕量刑情狀，也容易讓陪審員誤以為死刑量刑是數學問題，而不是一個道德決定¹²⁷。

除了前三個面向之外，*Steiker*報告尚且點名其他問題讓美國死刑制度問題重重，改革困難：（1）死刑被高度政治化。對於死刑制度的樣貌有形塑能力的檢察官、法官、州長與立法者承受相當大的

¹²⁶ *Id.* at 396-401.

¹²⁷ *Id.* at 401-04.

壓力，任何改革方案不容易被提出，從重量刑情狀的清單會被輕易地擴張。(2) 資源不足（特別是辯護資源），無法提供被告一個公平正當的刑事審判，更不要說保障被告之審判後的救濟程序¹²⁸。(3) 冤案難以平反與避免。研究顯示，死刑案件的冤案危險高於一般，但是政治部門往往會因為社會壓力或是財政考慮，對改革裹足不前¹²⁹。(4) 被告的聯邦憲法權利難以得到有效的保護。1970年之後的美國聯邦最高法院的判決以及美國國會通過的法律，大幅提高聯邦人身保護令的聲請門檻，使得在州法院被定罪的被告，難以透過人身保護令保障自身的憲法權利¹³⁰。(5) 死刑制度對於整體刑事司法制度具有負面影響。Steiker報告認為，由於聯邦最高法院過於著重於死刑制度，反而讓其他嚴刑峻法的刑事政策並未受到法院適當的監督¹³¹。

Steiker報告清楚地揭示了美國死刑制度為何「昂貴耗時，卻依然無法避免冤案與種族歧視的問題」、「鑑於現行頗為棘手之制度性與結構性障礙，難以確保死刑制度之運作擁有最低限度的適當性」¹³²，Steiker報告建議美國法律協會撤銷模範刑法典中的死刑條文，不應再投注時間與資源提出改革計畫，延遲大眾理解美國死刑制度的失敗¹³³。Steiker報告澄清，有些問題雖然同樣存在於其他刑罰種類中，但是，(1) 死刑與自由刑不能相提並論，畢竟死刑並非國家不可或缺的刑罰類型；(2) 那些存在於一般刑罰體系的問題，在死刑制度中更為顯著。例如：刑事案件的政治化問題，在死刑案件特別明顯；欠缺辯護資源，辯護人欠缺專業等問題，在死刑案件特別嚴重；(3) 死刑具有不可回復性，因而體制的錯誤更難被接

128 *Id.* at 404-08.

129 *Id.* at 408-10.

130 *Id.* at 410-15.

131 *Id.* at 415-20.

132 *Id.* at 367-68.

133 *Id.* at 370-72.

受，但在可預見的未來，死刑案件的誤判率難以被解決；(4) 鑑於死刑案件特別受到矚目，死刑體制的問題更會侵蝕大眾對於司法體制的信心，因而死刑必須受到特別的處置¹³⁴。

在討論過Steiker報告之後，美國法律協會於2009年10月正式撤銷模範刑法典中的死刑條文¹³⁵。美國法律協會雖然沒有明確地表態支持廢死，但撤銷模範刑法典裡頭的死刑條文，也有不再用協會的專業為美國死刑制度背書的意思。

(四) 廢止模範刑法典死刑條文後的美國

即便美國法律協會的模範刑法典是美國各州死刑量刑程序的範例，它畢竟不具備法律效力，因而美國法律協會撤銷模範刑法典中的死刑條文，並不會動搖於各州的死刑條文的效力。對美國社會而言，更為重要的是大家早已經意識到的——美國死刑制度「昂貴耗時，卻無法避免冤案與種族歧視」。剩下的問題只有，建立一個保障被告憲法權利、去除恣意與歧視，讓冤案可能性降到最低的死刑量刑程序，究竟在現實上是否可能？

在2010年後，美國有四個州廢除死刑，有四個州的州長停止死刑執行¹³⁶，這或許這是這些州對上述問題的答案。只是現實上美國還是有三十個州加上聯邦維持死刑，加上死刑議題具備高度政治性，人民的懲罰激情很容易受到單一事件的影響，誰也不能確保一個駭人聽聞的重大案件不會再度帶動更多的死刑判決與執行，甚至是死刑制度的恢復¹³⁷。因此，改革制度，讓死刑案件的審判可以避

¹³⁴ *Id.* at 374-75.

¹³⁵ *Id.* at 354.

¹³⁶ *See States with or without the Death Penalty*, DEATH PENALTY INFORMATION CENTER (Oct. 11, 2018), <https://deathpenaltyinfo.org/states-and-without-death-penalty>.

¹³⁷ 雖然有越來越多的國家廢除死刑，但學者也觀察到近年來出現所謂刑罰去文明化 (de-civilization) 的趨勢，一些本來因為文明化進程被揚棄的刑罰，在民眾情緒高漲的背景下，被重新恢復。*See John Pratt, Emotive and Ostentatious*

免冤抑，讓量刑可以去除恣意與歧視的制度，依然不少人權團體與自由派學者所致力的目標。種種環繞在美國死刑制度的政治現實，以及改革者對於正當法律程序與種族正義的堅持，使得已被美國法律協會廢棄之模範刑法典死刑量刑模式，持續在美國死刑制度扮演重要的角色。模範刑法典實踐的完整經驗，包括為了追求死刑量刑合理性與一致性所為的設計，以及實踐過程中因為意識形態或是政治結構所導致的問題，就成為他國借鏡時最好的參照對象。

肆、建構臺灣的死刑量刑基準

前一部分仔細地介紹了美國模範刑法典死刑量刑模式的身世，這個部分希望在前兩部分的基礎上進一步討論臺灣死刑量刑模式之建構。就臺灣當下死刑量刑實務所存在的各種問題，美國模範刑法典可以有什麼幫助？

一、定罪與量刑程序分離

在進入量刑模式的討論之前，首先處理一個死刑量刑程序的問題。模範刑法典第210.6條第2項將定罪與量刑程序區分開來，意即被告必須先在定罪階段被起訴的殺人罪定罪之後，法院方進一步對之進行是否判處死刑的量刑程序。與之對比，最高法院102年度台上字第170號刑事判決引用刑事訴訟法第288條第3項與第4項的規定，要求事實審法院將犯罪事實與科刑的辯論程序區分開來，以避免讓與犯罪事實無關的科刑資料影響法官認定事實的心證。此外，在司法院之《國民參與刑事審判法》草案中，第79條明文區分有罪

Punishment: Its Decline and Resurgence in Modern Society, 2 PUNISHMENT & SOC'Y 417, 417-39 (2000).

無罪與量刑的辯論程序，賦予當事人進行量刑辯論的權利¹³⁸。該條立法理由為「……按犯罪事實有無之認定，與應如何科刑，均同等重要，其影響被告之權益甚鉅，自應給予當事人就科刑範圍充分辯論之機會。爰明定當事人、辯護人就事實及法律辯論後，應就科刑範圍辯論之，俾量刑更加精緻、妥適。」不過草案第82條關於終局評議之程序，與現行刑事訴訟法（刑事訴訟法第299條至第310之3條）的做法類似，未來法官與國民法官的評議還是將定罪與量刑合併進行¹³⁹。

本文認為，最高法院與司法院草案的處理方式，雖然已經意識到定罪與量刑程序混淆可能產生的問題。只是，如果在判定被告有罪無罪之前，審判者已經聽過所有包括量刑的證據，光是將證據調查與辯論程序區分開來，希望量刑證據不會影響法官定罪的心證，實質來說並沒有意義。更大的問題是，被告在被定罪之前，就必須就量刑部分進行爭執，除了駁斥檢察官對他不利的證據之外，還必須請求調查對自己有利的證據，包括對犯行已經有所悔悟。除非被告自始認罪，否則很難在爭執無罪的同時，又提出證據證明她/他已有悔悟，或是向法院要求調查任何讓她/他看起來並不只是面目可憎之犯罪者的證據。因此，要讓量刑程序的調查對被告有意義，特別是希望審判者透過量刑程序看到活生生的社會人，就必須讓被告毫無罣礙，先確定有罪無罪之後，再給她/他一個單獨進行的量刑程序。這是為什麼在討論量刑模式之前，必須先處理量刑程序的

138 《國民參與刑事審判法》草案第79條（辯論）：「（第一項）調查證據完畢後，應命依下列次序就事實及法律分別辯論之：一、檢察官。二、被告。三、辯護人。（第二項）前項辯論後，應命依同一次序，就科刑範圍辯論之。（第三項）於科刑辯論前，並應予到場之告訴人、被害人或其家屬就科刑範圍表示意見之機會。已依前二項辯論者，得再為辯論，審判長亦得命再行辯論。」

139 《國民參與刑事審判法》草案第82條（終局評議之程序）：「（第一項）終局評議，由國民參與審判法庭法官與國民法官共同行之，依序討論事實之認定、法律之適用與科刑。……（第六項）評議時，應依序由國民法官及法官就事實之認定、法律之適用及科刑個別陳述意見。……」

原因。美國模範刑法典制定之後，第一個影響各州死刑實務的，就是定罪與量刑區分的程序規定。

事實上，如果真的要給被告一個毫無罣礙的量刑程序，不僅應將定罪與量刑程序區分開來，恐怕連量刑的審判者都必須跟定罪的審判者區不同才行，以避免被告在定罪階段積極爭取自己無罪之合法行使防禦權的行為，影響審判者對於被告犯後是否悔悟的判斷，進而影響被告的量刑。在死刑案件上，一點點的印象差別，往往就是生與死的距離。在這一點上，《麻州死刑報告》曾經建議可判死刑的被告倘若在定罪階段被定罪，在量刑階段有權利選擇新的陪審團¹⁴⁰。不過若要做到這一點，還必須搭配設計如何讓量刑的審判者理解被告罪行的相關情狀。進一步地，依照《麻州死刑報告》的規劃，一旦被告在量刑時要求不同的陪審團，就不能在量刑階段使用不同的心證門檻，要求量刑的陪審團在量刑階段針對被告的罪，考量是否仍有殘存不去的懷疑¹⁴¹。換言之，《麻州死刑報告》為死刑案件的量刑，就被告有罪無罪部分設計了更高的心證門檻。這個對被告是否有罪之殘存不去的懷疑，與模範刑法典第210.6條第1項第(f)款：「即便證據已足夠定罪，仍未排除對於被告罪行是否成立的疑問。」之規定接近。這些規定的哲學在於，死刑是一個與一般刑罰不一樣的處罰，因此必須格外的慎重。即便這樣的做法可能讓部分證人必須前後出庭，審判必須區分兩個階段，程序成本因此增加。

上述建議的程序，不管是定罪與量刑程序分離、在量刑階段更換不同的審判者，連帶採取不同的證據門檻等等，都沒辦法透過現行法的解釋達成。因而若要採取這些做法，非得修改現行刑事訴訟

140 《麻州死刑報告》之所以有此建議，與美國死刑量刑制度是在陪審制下發展出來的有關。但這個定罪量刑分離與陪審制並沒有邏輯上的關聯，因為即便

是由職業法官來審判，被告同樣難以一面爭執自己無罪，一面請求輕判。

141 Governor's Council on Capital Punishment, *supra* note 16, at 17-18.

法，以及修正《國民參與刑事審判法》草案不可。至於是否僅在定罪與量刑階段分開，或是從檢察官起訴求刑開始，就對可能判處死刑的案件建立一套不同的程序¹⁴²；以及是否僅就死刑案件建立一套不同的量刑程序，還是要全面性地讓刑事案件的定罪與量刑分離，則有討論餘地。死刑量刑程序應該要格外地慎重，但不代表一般案件之被告的利益不需要被重視。

二、採納從重量刑情狀與從輕量刑情狀的死刑量刑模式

就死刑量刑模式，本文主張採納模範刑法典的量刑方式，將量刑因子劃分從重量刑情狀與從輕量刑情狀，分層審查。目的在於避免現行死刑量刑實務中，（1）審判者依賴直覺決定何為情節最重大之罪、（2）被告犯後態度惡劣，影響對於被告是否犯下情節最重大之罪的判斷，以及（3）被告犯行嚴重，可能導致審判者對於被告是否個人有可減輕之因素毫無興趣等等量刑不一或不當的情況。

一旦採取模範刑法典的規定方式，檢察官首先必須在定罪階段證明被告犯下故意殺人罪。被告被定罪之後，在量刑階段，檢察官必須進一步舉證證明被告的犯行存在法律列舉之從重量刑情狀的其中一種，以取得判死的資格。而後審判者有義務調查案件是否不存在法定從輕量刑情狀，或是由辯方提出之其他足以請求寬貸之從輕量刑情狀。參照模範刑法典第210.6條第1項與第2項的規定，審判者可考量的對象並不限於該法律所列舉的情狀，與犯罪的本質與情狀、被告的人格、背景、歷史、心智與身體狀況有關的證據都可以提出。

（一）引入的好處

本文認為，臺灣引入此一從重量刑情狀與從輕量刑情狀的死刑

¹⁴² 參見李佳玟，死刑案件的審判程序——從《麻州州長死刑諮詢委員會報告》談起，全國律師，18卷5期，頁72-88（2014年）。

量刑模式，意義至少有三重。第一重，此種死刑量刑模式可以透過立法具體地定義何為「情節最重大之罪」，解決我國司法實務雖有盤點刑法第57條之外觀，但實質上仍由法官以直覺定義何為「情節最重大之罪」的問題。本文將公政公約之「情節最重大之罪」與模範刑法典之「從重量刑情狀」等同，是因為從規定方式與規定目的來看，模範刑法典的「從重量刑情狀」，除了(b)款關於被告前科（「被告曾有殺人罪前科，或是曾犯下涉及使用或威脅對他人使用暴力的重罪」）之外，大致上就是從犯罪情狀來界定何為「情節最重大之罪」，目的都是在將死刑限縮在那些最嚴重的罪行上。甚至模範刑法典自始就將死刑限定在殺人罪上，比起公政公約（「情節最重大之罪」）還必須透過人權委員會的解釋（「蓄意殺害並造成生命喪失」）來限縮，更為明確具體。採納模範刑法典的死刑量刑模式，「情節最重大之罪」將由立法者事先一般性地確定下來，未來審判中就不用就個案進行判斷，只要審查是否具備法定從重量刑事由其中之一就好。

本文認為，這種作法的優點還可以讓「惡中之惡」的決定具有民主正當性，節省司法透過一個又一個的案件累積犯罪類型的時間。並可避免法官在個案中，因為輿論或被害人的壓力，或是法官個人對特定犯行的感覺，導致判定標準不一的情況。畢竟一般性的立法可以進行各情狀的橫向比較，對照之下，在個案中若要進行橫向比較，很容易傷害被害人親友，並引起輿論批評¹⁴³。不過即便立法決定有上述好處，仍不能輕忽立法過程的輿論壓力，導致從重量刑情狀的清單不斷擴張，到可以包括絕大部分故意殺人罪的程度，Steiker報告就提供了美國的負面經驗¹⁴⁴；或是從重量刑因子不符合罪責原則，欠缺與刑罰目的之合理關聯的情況。因而要將這個做法引入臺灣，立法者仍有必要從公政公約希望限制死刑，以及刑罰必

143 參閱：法官認非最重大之罪 殺童魔免死，自由時報，2017年9月7日B02版。

144 Steiker & Steiker, *supra* note 72, at 395-96.

須合目的性等角度，仔細規劃從重量刑情狀的規定方式，避免出現「死刑量刑僅具有形式的標準，但實質卻存在立法恣意性」的問題。

第二重，引入模範刑法典的死刑量刑模式，可以將「情節最重大之罪」的決定與從輕量刑情狀的判斷區分為不同層次，如此一方面可以解決最高法院102年度台上字第5251號刑事判決所帶來的混亂。先前提到，最高法院102年度台上字第5251號刑事判決要求審判者透過盤點刑法第57條量刑事由的方式，判斷何為「情節最重大之罪」。如此一來，法官就必須在同一個層次裡盤點刑法第57條量刑事由，同時決定何為「情節最重大之罪」，以及從「活生生社會人」的角度評斷被告，這會造成盤點目的的混亂。原來想透過刑法第57條量刑事由之盤點，達到把被告放在社會脈絡下來量刑的目的，很容易被「情節最重大之罪」的判斷壓過。一旦採取從重量刑模式與從輕量刑模式，兩個不同層次的審查目的就可以明確地區分開來。另一方面，將兩個層次的判斷切開來，可避免讓本來並不是非常嚴重的犯罪，因為被告犯後態度特別惡劣，變成可判死的犯罪。最高法院102年度台上字第5251號刑事判決所要求的作法，的確存在這樣的可能性。而這種可能性，會讓某些自我放棄的被告，故意在審判時表現惡劣，讓法院判其死刑，實現其「司法自殺」的願望。

第三重，這個模式強迫審判者在可判死刑之罪除了審酌從重量刑情狀之外，還必須審酌從輕量刑情狀。姑且不論現實的操作是否「上有政策，下有對策」，這套量刑模式要求審判者即便面對情節相當重大的犯罪，還是必須審酌犯罪行為人的從輕量刑情狀。死刑雖然是一個仍有死刑的國家對應重大犯行的方式，然而，刑罰卻不能僅對犯行的嚴重程度做出反應。畢竟，刑罰是加諸於特定個人身上，因而犯行的嚴重程度就不可能不考量被告的狀況，才能夠對被告定出符合其罪責的刑罰。

（二）可能面臨的問題

雖然採納美國模範刑法典之死刑量刑模式有諸多好處，但參照美國經驗，採納此套模式可能會連帶面臨一些問題。

首先是關於從重量刑情狀的規定方式——臺灣是否要模仿模範刑法典第210.6條第3項第h款的規範方式（「殺人行為特別殘暴、窮凶惡極或殘忍，顯示被告異常的墮落腐敗」），這樣的規定方式會不會讓從重量刑情狀失去規範的邊界？其次，如何避免從重量刑情狀的清單不斷擴張？這兩種情況，很容易讓從重量刑情狀是要將死刑的適用，限制在「惡中之惡」的犯罪行為上的目的落空。美國聯邦最高法院數度處理過第一個議題，但並未處理第二個議題，即便學者已有批評¹⁴⁵。第三個問題是，Steiker報告曾指出，模範刑法典之從重量刑情狀與從輕量刑情狀背後所代表的量刑哲學存在緊張關係。意即一旦允許審判者就個案作毫無邊際的量刑因素考量，當初希望設下從重量刑情狀，讓量刑可受指引規範的目的就可能會落空，這個問題該如何解決？第四個問題是，Steiker報告指出，即便各州仿照模範刑法典規定量刑必須考量從重量刑情狀與從輕量刑情況，陪審團不見得理解這個模式如何操作，或是願意遵照這個模式量刑。最後，美國法律協會之所以撤銷模範刑法典中的死刑條文，是因為採行模範刑法典死刑量刑模式的美國死刑制度，問題重重，改革困難，「昂貴耗時，卻依然無法避免冤案與種族歧視的問題」，本文主張引入這個模式，必須回應上述的問題。

145 See Jonathan Simon & Christina Spaulding, *Tokens of Our Esteem: Aggravating Factors in the Era of Deregulated Death Penalties*, in *THE KILLING STATE: CAPITAL PUNISHMENT IN LAW, POLITICS, AND CULTURE* 81, 81-113 (Austin Sarat ed., 1999); Jeffrey L. Kirchmeier, *Casting a Wider Net: Another Decade of Legislative Expansion of the Death Penalty in the United States*, 34 *PEPPERDINE L. REV.* 1 (2006).

1. 法定從重量刑情狀的規定方式

(1) 麻州死刑報告的作法

如果說從重量刑情狀的規定是為了限縮死刑適用的範圍，讓死刑只用在「惡中之惡」的犯行上，那麼，從重量刑情狀的規定是否夠明確，就會影響其概念目的是否能達成。在這個問題上，仿照模範刑法典第210.6條第3項第h款（「殺人行為特別殘暴、窮凶惡極或殘忍，顯示被告異常的墮落腐敗」）的規定方式問題最大。設計這一款的人或許擔心前7款的列舉規定會掛一漏萬，會出現讓眾人憤慨，但又無法判死的情況。但訴諸審判者感覺與評價的文字，很容易導致適用結果標準不一。即便此種規範方式沒有自始違憲，立法者在設計規範時，也必須盡量讓適用範圍精確。

對照模範刑法典的作法，2004年《麻州死刑報告》對得判死刑的殺人類型做了相當嚴格的限縮，除了必須是行為人在犯罪時已滿18歲，故意殺害被害人之外，該報告設下六種情狀，包括：

(a)被告之殺人行為乃是一種政治恐怖主義的行動；(b)被告殺人之目的在於影響、妨礙、阻擾、牽制、延緩、懲罰，或以他法干擾犯罪之偵查、大陪審團的程序、審判，或其他刑事程序的進行；(c)在殺人進行當中或緊接殺人之前，被告故意長時間且以無端又墮落腐敗（*gratuitous and depraved*）的手法虐待被害人；(d)被告所犯之一級殺人行為中有兩名或多名被害人；(e)被告曾在麻州或在其他美國司法管轄區已因一級殺人罪被定罪，而且過去的殺人行為皆符合上述(1)至(3)之要件；(f)在被告犯下符合上述(1)的殺人行為時，已因於麻州或美國其他的司法管轄區的所犯的殺人罪而被判處終身監禁不得假釋¹⁴⁶。

¹⁴⁶ 在《麻州死刑報告》中，得判死刑的殺人行為為：(1)被告採用下列手段殺

雖然模範刑法典也用了評價性字眼，但除了條文將該評價性字眼明確地針對犯罪手段之外，報告也做了進一步的解釋——「虐待」意指在被告知道被害者有意識的情形下，在生理或心理上施加極端的痛苦。「無端又墮落腐敗」意指這樣的痛苦超過殺害行為本身所必需，或被告為造成這樣的痛苦而選擇此種特定的殺害方式。而後在條文的立法註釋裡，報告又提供下列說明：

(4)(c)第三類加重事由乃是設計出一種較現行麻州法規中「第一級謀殺」之「極度殘暴或殘忍」範疇更窄的虐待式謀殺。這類加重事由限於(1)施加生理或心理極度的痛苦、(2)持續一段非常久的時間、(3)發生在犯罪期間或緊鄰於犯罪進行之前、(4)施虐時被告知道被害者尚有意識、(5)是「故意的」，意指被告有意識地希望施加這樣的苦痛，以及(6)是「無端且墮落腐敗」，意指這樣的痛苦超過殺害行為本身所必需或被告有意地選用這種特別痛苦的殺害方式。若要主張被告存在本項的加重事由因而得以判處死刑，必須證明這六個子要件全部存在。在謀殺前對被害者性侵害，如強暴或雞姦，得在特定案件中構成施予「極端的心理痛苦」。將虐待限制在「謀殺時或緊鄰於謀殺進行前」是為了排除被告在較早的時候對被害者施虐的案例（例如：在夫妻間的謀殺案件中，被害人可能在更早的時候就遭到家庭暴力）。限制「被告知道受害者是尚有意識的」，是為了回應現行的麻州案例法，該法主張即使在受害者是無意識的情形下，仍然可以滿足「極度殘暴或殘忍」的要件¹⁴⁷。

人：(a)被告以己身之行為；(b)他人因被告之指示或控制而進行；或(c)他人因與被告共謀而殺人；以及(2)被告行為前已有預先計畫惡意殺害被害人(deliberately premeditated malice aforethought)，造成被害者之死亡；而且(3)被告為下列任一行為時已滿18歲：(a)以己身之行為造成被害者的死亡；(b)指示或控制他人殺人；(c)與他人共謀，促使該人殺人。第(4)點就是正文提到的那六種情狀。Governor's Council on Capital Punishment, *supra* note 16, at 6-7.

¹⁴⁷ *Id.* at 8. 中文版翻譯引用Governor's Council on Capital Punishment，陳匡正譯，

《麻州死刑報告》的這種立法方式，算是一個折衷做法，它不仰賴法院對於抽象條文的指示，但也不揚棄用抽象概括的方式描述從重量刑情狀。這個報告在法條裡試圖建構一個清楚的標準，此種做法相當程度滿足本文先前所說，即便使用評價性的文字去處理無法事先預料的情況，立法者有義務讓適用的範圍精確，並提供具體的立法解釋。

(2) 臺灣應採取的作法

Steiker報告所在意的是從重量刑因素的規定方式若不節制與清楚，將會使得當初Furman案與Gregg案判決希望約束死刑裁量權的期待無法達成，而美國死刑制度中的種族歧視不僅無法縮減，還因為死刑範圍寬鬆、制度複雜，更難被處理。臺灣雖沒有像美國那麼明顯的種族問題，但死刑量刑的裁量權若沒有受到適當的限制，依然會有標準不一，「被判死的人不是最該死的人」的可能性。

因此，未來若要把模範刑法典的死刑量刑模式引入臺灣，就從重量刑情狀，應避免使用抽象概括的規範方式。建構列舉清單時不應直接引入美國法，而應建構本土之情狀最重大之罪的清單。建構時或可參考我國實務曾提出的例子或標準，譬如最高法院105年度台上字第984號刑事判決（「犯罪行為動機是否具倫理特別可責性（例如嗜血殺人魔、謀財害命、性癮摧花或其他卑鄙動機等）、犯罪手段或情節具特別殘暴性、行為結果具嚴重破壞性、危害性等」），或是最高法院102台上第170號刑事判決曾引用的學說研究，甚至是檢察總長顏大和於2017年為王鴻偉提起的非常上訴的意見，畢竟這是我國實務工作者曾經認可的類型，相當程度反映了一些價值選

李仰桓、李佳玟校譯，麻州州長死刑諮詢委員會的最終報告，頁8，臺灣廢除死刑聯盟，2005年，https://www.taedp.org.tw/sites/default/files/ma_zhou_zhou_chang_si_xing_zi_xun_wei_yuan_hui_bao_gao_final.pdf（最後瀏覽日：2018年8月30日）。

擇。若還是希望採取模範刑法典第210.6條第3項第h款的規範方式，重點應該仿照《麻州死刑報告》的處理方式，盡量在文字上讓死刑的適用範圍精確，並對評價性的用語提供詳細的立法解釋。就從重量刑情狀的立法方式，建議在刑法第57條之外另立新的條文。既有之刑法第57條，可作為那些非法定列舉量刑因子的法律基礎。

至於如何避免列舉的從重量刑清單一開始就過長，或是之後不斷擴張，或是出現一些違反罪責原則、重複評價原則，毫無刑罰目的思考的個別量刑因子？對於過度擴張的從重量刑清單，能否讓大法官介入審查，作為監督的機制？本文以為，除非死刑制度根本被宣告違憲、死刑量刑模式明顯允許審判者濫用裁量權，或是個別量刑因子違反罪責原則或重複評價原則，否則，大法官插手的機會不多。針對「從重量刑情狀清單過長，或是之後不斷擴張」的問題，只能借鏡美國經驗，說明「從重量刑情狀浮濫與量刑歧視恣意」之間的連結，以節制擴張死刑門檻的慾望。於模範刑法典之死刑量刑模式引進之後，則依賴學者進行類似*McCleskey v. Kemp*案的Baldus實證研究，辨認臺灣死刑制度是否因為量刑模式衍生系統性歧視等問題，在立法過程中引用實證資料，阻止或是廢除不當的從重量刑情狀立法。這些說服的工作，與其說是引入模範刑法典死刑量刑模式所增加的麻煩，不如說是，為了讓死刑量刑更有結構，為了審判者的裁量權限受到適當的限制，改革者所必須做的努力。

2. 量刑準則內部的緊張關係

採用模範刑法典之死刑量刑模式可能面臨的第二個問題，在於這套模式所立足的量刑哲學——透過法條羅列量刑因子，但允許審判者在從輕量刑事由上可以廣泛考量，使得審判者的量刑裁量權一方面可以受到限制，一方面讓死刑量刑能夠個別化的做法，是否本質上存在矛盾？

(1) 美國實務與學界對此問題的討論

這個問題在模範刑法典實踐的過程中曾被清楚地指出，雖然攻擊的對象並非針對模範刑法典，而是針對與模範刑法典有同樣邏輯的標竿性判決——*Gregg v. Georgia*案。

在前一個部分引述Steiker報告對於美國死刑制度的批評時，本文就曾提到，美國聯邦最高法院在*Gregg*案發展出的兩個量刑指導法則——讓審判者的量刑裁量權受到指導，以及死刑量刑能夠個別化，被批評兩者之間存在緊張關係。若陪審團可不受限制的考量各種法定與非法定的從輕量刑事由，希望審判者裁量權受到指導與規範的期待就會被架空。Steiker報告所針對的雖然是*Gregg*案判決所建構的兩個量刑指導法則，其實也講到模範刑法典的量刑哲學，畢竟*Gregg*案中，喬治亞州即是仿照模範刑法典的死刑量刑規定。根據模範刑法典第210.6條第1項之規定，只有在案件具備該條第3項的從重量刑情狀，以及不具備可請求寬貸之具有相當份量的從輕量刑情狀，審判者才可以判處被告死刑。模範刑法典明確地限制判死資格的審酌對象，但並未限制審判者只能考量該法定從輕量刑情狀。

另外，Steiker報告並沒有明確指出，但也對美國死刑量刑第二階段之不確定性「作出貢獻」，還包括非法定的從重量刑證據。所謂非法定的從重量刑證據，是指與判死的資格審查無關，但對被告不利的證據，譬如被害人影響陳述。模範刑法典並沒有明確定位非法定的從重量刑證據的地位，但第210.6條第2項規定「在量刑程序中，任何法院認為與量刑有關之事項的證據均可被提出，包括（但不限於）犯罪的本質與情狀、被告的人格、背景、歷史、心智與身體狀況，以及任何本條第3項與第4項列舉的從重量刑與從輕量刑情狀。」似乎允許檢察官提出非法定的從重量刑證據。美國聯邦最高

法院在1983年的*Zant v. Stephens*¹⁴⁸與*Barclay v. Florida*¹⁴⁹兩個判決裡指出，憲法並未禁止審判者在量刑階段考慮非法定從重量刑情狀的資訊，只要這些資訊與被告的人格或是犯罪情狀有關，畢竟在量刑階段必須要做個別化的決定。由於美國聯邦最高法院亮了綠燈，美國不少的死刑州准許檢察官引入非法定的從重量刑證據。除了被害者影響陳述作為犯罪的影響證據之外，還包括被告對於社會的未來危險性、被告是否悔悟等證據¹⁵⁰。Jeffrey L. Kirchmeier教授批評，對從重量刑證據不設限，讓死刑量刑回復到*Furman*案與*Gregg*案之前的情況¹⁵¹。

事實上，在*Furman*案與*Gregg*案前一年，美國聯邦最高法院在*McGautha v. California*案的判決還否定設立死刑量刑法則¹⁵²。主筆的John Marshall Harlan大法官主張，由於一個案件有太多的事實面向，人類無法窮盡所有與量刑相關的因素，因此為陪審團設立量刑準則超越人類的能力¹⁵³。不過隔年的*Furman*案裡，美國聯邦最高法院改變立場，推翻*McGautha*案判決，美國聯邦最高法院朝向建立一套量刑準則的方向，*Gregg*案判決確立兼顧讓審判者的量刑裁量權受到指導，以及死刑量刑能夠個別化的作法。但這兩個法則之間的緊張關係，在*Gregg*案判決做出的10年之後慢慢顯現出來。美國聯邦最高法院有幾個大法官對於這個議題曾先後表態，各有想法。

148 See *Zant v. Stephens*, 462 U.S. 862 (1983).

149 See *Barclay v. Florida*, 463 U.S. 939 (1983).

150 CARTER, KREITZBER & HOWE, *supra* note 83, at 149-50.

151 Jeffrey L. Kirchmeier, *Aggravating and Mitigating Factors: The Paradox of Today's Arbitrary and Mandatory Capital Punishment Scheme*, 6 WM. & MARY BILL RTS. J. 345, 375-86 (1998).

152 See *McGautha v. California*, 402 U.S. 183 (1971).

153 *Id.* at 208.

Antonin Scalia大法官是拒絕個別化量刑派。他宣稱第二個原則「個別化量刑」破壞了第一個原則「受指導的裁量權」可以有的一致性¹⁵⁴。他認為這兩個原則並不只是存在緊張關係而已，而是有根本的矛盾。他因此宣告他之後不再以「裁判者的量刑權限受到不當限制」宣告某些州的量刑法則違憲¹⁵⁵。Harry Blackmun大法官是廢除死刑派。他指出：「任何可以有效地抑制死刑恣意性的法條或程序，將會限制審判者的裁量權，讓審判者無法充分地考量個別犯罪者的獨特個性以及犯罪的情狀。同樣地，任何想要提供審判者足夠的裁量權，好讓他們去充分考量犯行與犯罪者的獨特情狀時，將會開了一個後門，讓量刑變得恣意與不理性。」Blackmun大法官認為兩個原則對於死刑制度之合憲性的維持都相當重要，既然兩者之間的矛盾無法被解決，死刑的量刑因此不可能符合美國憲法的要求，因此死刑制度應該被放棄，他從此拒絕對死刑制度進行調整校正¹⁵⁶。

John Paul Stevens大法官則是折衷改革派。他認為，處理兩個法則間之緊張關係的方式，就是將死刑限縮至很小的範圍。意思是，在個別化量刑的層次，無法避免審判者的恣意。但若能將可判死刑的案件嚴格限縮，起碼可以縮小問題的範圍¹⁵⁷。

(2) 本文意見

本文認同Blackmun大法官的觀察：「任何可以有效地抑制死刑恣意性的法條或程序，將會限制審判者的裁量權，讓審判者無法充分地考量個別犯罪者的獨特個性以及犯罪的情狀。同樣地，任何想要提供審判者足夠的裁量權，好讓他們充分考量犯行與犯罪者的獨

¹⁵⁴ Walton v. Arizona, 497 U.S. 639, 661 (1990).

¹⁵⁵ See, e.g., Lockett v. Ohio, 438 U.S. 586 (1978).

¹⁵⁶ Callins v. Collins, 510 U.S. 1141, 1155 (1994) (Blackmun, J., dissenting).

¹⁵⁷ Walton v. Arizona, 497 U.S. 639, 716-18 (Stevens, J., dissenting).

特情狀時，將會開了一個後門，讓量刑變得恣意與不理性。」這大概是所有意圖設立量刑準則之改革者所面臨的難題。之所以會是難題，關鍵點在於Blackmun大法官所指出的，量刑一致性與個別化都是憲法的要求，偏一不可。我們既不希望審判者恣意量刑，不受任何約束的裁量權將會對弱勢者與社會邊緣人不利；我們也不希望裁判者看不到犯罪者本身，同樣罪名下，有不同的犯罪情狀。一個好的死刑量刑基準，應該要鼓勵，甚至是要求審判者直視犯罪者，將犯罪者放到社會脈絡去觀察，從應報或從道義的角度衡量個別案件的可罰程度，也從個別預防的角度思考刑罰的必要性，死刑量刑因此非得個別化不可。

面對這兩個即便不是矛盾，也至少存在高度緊張關係的要求，1962年提出的模範刑法典算是一個大膽的嘗試。它不限制審判者考量非法定的從重量刑情狀與從輕量刑情狀，但它先把特定的從重情狀挑出，限制審判者只有在滿足這些情狀其中之一時，被告才有判處死刑的資格。模範刑法典的做法讓本來混沌的死刑量刑開始有個裁量的順序與依據，而且還是具體的依據，跨出讓死刑量刑標準一致的第一步。它讓法定從重量刑情狀單獨出來考量，與其他量刑因子切開，可以排除其他事後因素對於該案件是否有被判處死刑資格產生干擾，這個讓量刑結構化的作法，是讓死刑量刑標準趨於合理與一致的第二步。

模範刑法典設計者所採取的第三步是，模範刑法典雖然沒有限制審判者考量非法定的量刑因子，但法典對於從輕量刑情狀的規定並非沒有意義。鑑於每種量刑因子對於刑罰的判斷究竟是正面或是負面，不同的審判者可能有不同的評價。譬如被告受到酒精的影響，也有可能被檢方當作是被告欠缺自制力，對社會存在相當大的危險，成為判處死刑的正面因素。臺灣沒有一定要仿效模範刑法典第210.6條第4項規定內容，可以自訂法定從輕量刑情狀，但該項的法定從輕量刑情狀示範了一種立法方式，允許立法者預先規定某些

量刑因子該怎樣被評價。這個清單與法定從重量刑情狀一樣，可以經過一般性的抽象討論，具有較高的民主正當性。

剩下的問題在於，模範刑法典所設計的量刑模式，是否因為對於非法定的量刑因子不設限（但至少要跟犯罪人與犯罪行為有關），使得意圖透過這套量刑基準達到量刑一致性的目標自始被架空。模範刑法典所設計的方式，是否依然讓死刑量刑充滿恣意，只是隱藏在看來複雜的量刑基準後面？如同*McGautha*案的法庭之友身意見書所說——「如果你願意，你就可以殺了他（Kill him if you want）」，跟「你可以殺了他，但如果你願意，你可以放過他一馬（Kill him, but you may spare him if you want）」，本質其實並無不同¹⁵⁸？

本文認為*McGautha*案的法庭之友誇大了這兩個情況的類似性，倘若不採取任何量刑基準，在當年，審判者其實有可能對於最平常的鬥毆殺人判處死刑。採取量刑基準之後，至少這些平常的殺人行為可以被排除。「如果你願意，你就可以殺了他」，跟採取模範刑法典之後，「你可以殺了他，但如果你願意，你可以放過他一馬」，死刑適用的範圍是不一樣的。從這個角度來看，若真的要削減模範刑法典之量刑模式仍存在的的不確定性，*Stevens*大法官的建議的確是唯一的出路：儘量限縮從重量刑情狀的清單。

不過或許更根本的是，我們必須認識到，量刑基準可做的事本來就有其極限。姑且不說我們對於量刑基準的期待本來就存在緊張關係，量刑基準本來就是在挑戰一個不可能的任務，不只因為每個案件有不同的事實面向，涉及不同的犯罪者與被害人；更因為每個人對於特定因素的價值判斷不一，法律至多只能針對有共識的部分

158 See Brief Amici Curiae of the NAACP Legal Defense and Education Fund, Inc., and the National Office for the Rights of the Indigent at 69, *McGautha v. California*, 402 U.S. 183 (1971) (No. 71-203)，轉引自STEIKER & STEIKER, *supra* note 74, at 377 n.25.

先做規定，立法者尚且不能規定特定從輕量刑因素與其他量刑因子衡量之後的結果。除非我們自信能夠窮盡所有的量刑因子，並對各個量刑因子做出特定、不變的評價，讓量刑變成數學的加減。無法廢除死刑，因此必須有量刑基準是改革的極限，而量刑標準難以讓死刑量刑標準絕對一致，這是人類司法體制的極限。

如果是這樣，本文當初對於刑法第57條的批評是否公允？先前的批評主要有兩點：（1）刑法第57條只要求法官調查某個面向，卻沒有規定需要調查地多深，需要多少的證據才能夠完整地說明犯罪的動機、目的等等，審判者究竟有多少的調查責任。（2）刑法第57條沒有告訴法官個別因素對於死刑的決定究竟是正面或是負面，這條更沒有說各款之間的關係為何，要如何權衡。針對第二個批評，可以確定模範刑法典的量刑模式還是優於我國刑法第57條。理由是，相較於刑法第57條只有描述量刑可以考慮的面向，模範刑法典的死刑量刑模式提供了具體情狀的指引；相較於刑法第57條把所有跟犯罪行為與犯罪人有關的量刑因子規定在同一個條文，一起進行衡量，模範刑法典規定了量刑的層次，採用模範刑法典會給審判者的量刑裁量權比較多的指引。但兩者共通的地方在於，某些非法定量刑因子對於死刑的科處是正面或負面，要如何衡量各個量刑因子，刑法第57條或是模範刑法典第210.6條都沒有處理。

至於第一個批評：「刑法第57條只要求法官調查某個面向，卻沒有規定需要調查地多深，需要多少的證據才能夠完整地說明犯罪的動機、目的等等，審判者究竟有多少的調查責任。」本文認為，這個問題，即便採取模範刑法典之從重與從輕量刑模式也難以避免。不過，量刑深度的部分雖然難以透過立法要求，倒是可以仿效模範刑法典關於量刑報告的規定，提供更多的資料給審判者，誘導量刑的深度。

在第210.6條第2項的另一種由法院決定的程序裡，規定了「除非法院依本條第1項科予被告一級重罪之刑罰，法院應當透過分開的程序決定被告應被判處第一級重罪或是死刑。在此程序中，法院應依據本法第7.07條審酌量刑前的調查報告。」依照模範刑法典第7.07條之規定法官量刑前應考量量刑前的調查報告（簡稱量刑報告），量刑報告包括被告的犯罪前科、犯罪的相關情狀、被告之非行歷史、身體與心智狀況、家庭情況與背景、經濟條件、教育、職業、個人習慣或是任何假釋官認為相關，或是法院命令必須包含的資料。在量刑前，法院可命被告接受60日以下的精神觀察與檢查。在量刑之前，法院應告知被告與其辯護律師關於量刑報告或是精神檢查的內容或結論，並提供被告與其律師反駁的機會。本文認為這類報告並不妨礙檢察官與被告各自提出證據的權利，但可提供審判者一個全面理解被告的機會，有助於審判者以人格如何形成的角度觀察被告，給予被告較為周全的刑種與刑度¹⁵⁹。

除此之外，一旦引入模範刑法典的死刑量刑模式之後，還有很多程序細節必須討論，包括（1）量刑情狀的舉證標準為何？法定從重量刑情狀與法定從輕量刑情狀的舉證標準是否相同（美國有些州就規定法定從重量刑因子的存在，必須超越合理懷疑）？非法定

¹⁵⁹ 最高法院107年度台上字第480號刑事判決即採取這樣的見解（「刑之量定，乃法律賦予法院自由裁量之事項。法院於科刑時，應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意刑法第57條所列各款事項，以為科刑輕重之標準。此項科刑審酌之具體情形，自應依刑事訴訟法第310條第3款規定，於判決理由內為記載。再法院對被告進行量刑或處遇方案之審酌，而囑託鑑定人以被告之犯罪要件事實以外之事實情狀，提供法院相關必要資訊之鑑定時，該相關情狀之鑑定事項常涉及多樣之多層面因素，諸如被告之性格、家庭背景、生活經歷、成長環境、本件犯罪動機、犯後心理狀態、犯罪人之身危險性及再犯可能性預測，甚至日後之處遇方案選擇、處遇成效等分析。其評估內容往往跨越單一領域，而含括心理學、犯罪學、社會學、精神醫學等專業，自需借助理師、醫師、社工師、保護觀察官等專門人士於判決前進行綜合性之團隊鑑定調查，以客觀提供法院作為決定刑度及處遇內容之依據，並可避免單一鑑定人之主觀定調。」）

量刑因子的舉證標準是否也類比法定量刑因子的證明？（2）由誰負擔主要的說服責任？是辯方必須證明從輕量刑因子大於從重量刑因子，還是控方必須證明從重量刑因子大於從輕量刑因子？（3）從重與從輕情狀的權衡若五五波，結果為何？（4）國家是否擔負協助被告提出從輕量刑因子的義務？例如：國家是否有義務提供被告心理學家，以證明被告具有精神與情緒障礙？（5）一旦允許第二個層次考量非法定的加重量刑證據，審判者所要回答的問題究竟是什麼？或是更具體地說，這個部分量刑究竟是在追求什麼刑罰目的？在這個層次是否仍可以考慮應報或一般預防的問題，還是只能思考個別預防？關於量刑目的是否也能事先規定，還是由最高法院在判決中形成就好？限於篇幅，這些程序細節還待後續的研究來補充。想要提醒的是，這些議題的作法將會影響模範刑法典之死刑量刑模式的實踐狀況。模範刑法典在美國的實踐情況，已經告訴我們程序細節往往是一個制度的成敗關鍵。

3. 量刑理想與量刑現實的差距

採行模範刑法典量刑模式必須面對的第三個質疑是，即便仿照模範刑法典，於法律中詳細規劃死刑量刑方式，審判者不見得理解這個模式如何操作，或是願意遵照這個模式量刑，種種現實問題都會讓引入模範刑法典死刑量刑模式所希望的變革落空，Steiker報告引證不少研究，指出美國死刑量刑實務的確存在這樣的問題。

本文同意，上有政策下有對策是所有改革者的惡夢。然而，在改革前就看到改革方案被人性架空的可能性，不是拒絕採取特定改革方案的理由，而是提醒改革者讓改革更為細緻，並提前因應。包括參考其他國家的經驗，分析其他國家為何曾經改革失敗。或是與專家（譬如審判心理學家）合作，思考應該要給審判者什麼樣的輔助，才可以讓審判者不在定罪階段就下了判死刑的心證，更換不同的審判者（或陪審團）會不會是唯一的解方等等。至於其他問題，

譬如不了解從輕量刑情狀的意思，如何作用，可以考慮透過研修會讓實務工作者理解新制度，並對國民法官進行審前教育來避免誤解。或是透過個案審判長的說明，讓國民法官理解死刑量刑並不是從重量刑情狀與從輕量刑情狀之間加加減減的數學問題，而是一個必須跟其他人一起面對人性黑暗面，追問自己價值，與何為這個社會的價值之道德決定。

4. 昂貴耗時，無法避免冤案？

最後，主張引入模範刑法典無可避免的質疑是，美國法律協會以此一模式「昂貴耗時，卻依然無法避免冤案與種族歧視的問題」，撤銷模範刑法典中的死刑條文，拒絕再為此一制度背書，臺灣適當引入別人已經放棄的制度嗎？臺灣雖沒有像美國社會的種族問題，但臺灣死刑制度存在冤案的隱憂，譬如成功翻案的徐自強案、鄭性澤案，或甚至是近年才被執行，爭議相當大的杜氏父子案。如果美國的這個量刑模式昂貴耗時，又無法避免冤案的問題，臺灣應該要引入嗎？

從Steiker報告來看，美國死刑制度之所以無法擺脫冤案的問題，有些來自於量刑準則本身，有些與量刑準則無關。與量刑準則有關的，是先前提到的從重量刑因素標準過於模糊，導致幾乎所有的故意殺人行為都成為可以判死的對象。由於可被判死刑的範圍相當大，再加上為了讓裁判個別化，模範刑法典允許審判者不受限制地考量任何與犯罪者及犯行有關的因素，在這樣的量刑架構下，種族偏見特別容易滲入。不只是黑人被告相對於白人更容易被求處死刑，從已被平反的死刑案件來看，不少都是黑人被指控強姦殺害白人被害人。換言之，美國的冤案與種族因素緊密相關。然而面對美國死刑體制存在種族歧視的挑戰，美國聯邦最高法院卻無法提出適當的法則解決，甚至為此類挑戰設下相當高的門檻。

與量刑方式無關，但與冤案問題息息相關的是「翻案」門檻，律師協助等刑事司法程序本身的問題。就翻案門檻，美國聯邦最高法院要求被告先向州法院要求救濟，只有在滿足相當高的證據門檻，才能向聯邦法院提出人身保護令的要求。對於死刑案件被告至關重要的律師協助，美國聯邦最高法院不是對於被告之「無效律師協助」的主張設下頗高的門檻，就是對於定罪之後上訴的律師協助毫無審查標準。**Steiker**報告指出，由於死刑被高度政治化，立法者承受相當大的壓力，不僅任何改革方案不容易被提出，死刑從重量刑情狀的清單容易在民意壓力下擴張。

針對前述**Steiker**報告所提出的問題，若對照臺灣社會狀況來看，最需要擔心的，是因為政治壓力使得從重量刑情狀的清單被擴張，從酒駕致人於死被詮釋成「酒駕殺人，因此應判死刑」的修法爭議來看¹⁶⁰，的確有這樣的可能。立法者有可能在民意壓力下，增加可判死的類型，並對於從重量刑情狀設下模糊的概括標準，這是本文何以提出《麻州死刑報告》作為參照的原因，《麻州死刑報告》展現美國死刑改革者如何在模範刑法典的基礎上，讓死刑制度理性化。這也是本文主張未來若將模範刑法典之死刑量刑模式引入臺灣，學界、司法實務界、政治人物與大眾必須進行對話，避免納入違反罪責原則、重複評價原則，毫無刑罰目的思考的量刑因子。酒駕致死後來的修法結果（不能單以酒駕累犯作為判處死刑的因素），顯示刑法學界的努力，在民意的壓力下並非毫無作用¹⁶¹。

至於那些與量刑模式無關，可能導致冤案的因素，本文對於臺灣社會的狀況有比較多的信心。首先就翻案門檻，由於諸如個別冤

160 例如：彭緯琳、呂雪慧，將比照《刑法》殺人罪或傷害罪 酒駕奪命 最重可判死刑，工商時報，2019年3月29日A4版。

161 林上祚，酒駕殺人累犯最重死刑行政院踩煞車 羅秉成：兩公約簽署後刑度不得提高為死刑，風傳媒，2019年3月28日，<https://www.storm.mg/article/1112790>（最後瀏覽日：2019年5月26日）。

案的衝擊，立法院於2015年將《刑事訴訟法》第420條以新事實、新證據聲請再審的認定條件放寬，司法院於2019年進一步提出《刑事訴訟法》修法草案，對於再審程序有更為細緻化的規範，包括新增再審聲請人閱卷權的規定，改變書面審理的做法，要求法院開庭，給予聲請人陳述意見的機會，並賦予聲請人向法院聲請調查證據之權利，以及法院得視情況依職權調查證據¹⁶²。雖然法律尚未通過，但從媒體給予正面報導的情況來看¹⁶³，相當程度代表著臺灣社會的再審議題不會像美國，減少冤案的改革比較容易。至於死刑案件被告受律師協助，雖然輿論不乏被害人沒有律師協助，反倒是法律扶助基金會卻可以派出三個律師協助死刑案件被告的批評¹⁶⁴，但對於法扶制度的改革，重點其實在於如何不讓有錢的被告濫用法扶資源¹⁶⁵，以及法扶預算的控制¹⁶⁶。被害保護的議題，則透過被害人訴訟參加制度中，提供被害者訴訟協助作為對應¹⁶⁷。

另一個必須留心的差異，是兩國政治體制與司法體制的差異。美國採行聯邦體制，各州與聯邦各有自己的刑事司法體制；而臺灣採行中央政府體制，只有一套刑事司法體制，這使得兩國的制度改革者需要面對的改革阻力不同。美國法律協會難以期待各死刑州與

162 司法院刑事廳，司法院第176次院會通過刑事訴訟法再審部分條文修正草案新聞稿，2019年4月22日，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=446313>（最後瀏覽日：2019年5月26日）。

163 例如：楊國文、陳鈺馥，給冤獄開一扇窗 再審規定將放寬，自由時報，2019年5月7日A01版。

164 吳政峰、鮑建信、張文川，派3律師幫死刑犯求活 法扶會挨轟浪費資源，自由時報，2018年2月10日B01版。

165 劉志原，【法扶遭濫用】年燒10億公帑 法扶幫吸金百億被告打官司，鏡傳媒，2017年8月15日，<https://www.mirrormedia.mg/story/20170814inv002/>（最後瀏覽日：2019年5月26日）。

166 劉志原，【法扶遭濫用】律師拿過高委任費 法扶成全國最大事務所，鏡傳媒，2017年8月15日，<https://www.mirrormedia.mg/story/20170814inv003/>（最後瀏覽日：2019年5月26日）。

167 司法院刑事廳，司法院「犯罪被害人訴訟參與制度及保護規定草案初稿」發布記者會新聞稿，2017年12月28日，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=305627>（最後瀏覽日：2019年5月26日）。

聯邦都能有合理的改革，但臺灣的法律人卻只要針對一套法律制度來努力。本文並非暗示臺灣刑事制度的走向可以比較受到法律人的控制，臺灣死刑制度要改革比較容易，各有各的難處。但是，若從美國死刑制度冤案的成因（包括難以翻案之因素）來看，臺灣在律師表現與再審制度上比較不需要擔心。美國法律協會放棄死刑制度的改革有其背景，臺灣卻無妨引入這套模式，讓死刑量刑從形式被理性化。

三、教化可能性的去留

引入模範刑法典的死刑量刑模式，某程度可說是在可判死刑的案件裡，用從重與從輕量型情狀模式取代刑法第57條原先在死刑量刑所扮演的角色。於我國引入這個模式的最後一個問題是，原先吳燦基準裡最後一關對於教化可能性的實證調查，是否因此隨著吳燦基準一併捨棄？還是說，鑑於教化可能性這個量刑因子是在恤刑的框架下被提出，它追問死刑的必要性，讓死刑的量處更為嚴謹。是以未來引入模範刑法典的死刑量刑模式，是否依然保留教化可能性的調查，作為量刑審查的第三階段？美國實務在思考死刑議題時，是否也在意被告的教化可能性？

（一）美國實務對於「未來危險性」的使用與相關質疑

模範刑法典與美國司法實務都沒有「教化可能性」這個用語，但美國司法實務有個跟「教化可能性」概念接近的「未來危險性」（future dangerousness）這個量刑因子¹⁶⁸，廣泛存在死刑量刑實務中，並受到美國聯邦最高法院的支持。

¹⁶⁸ 在我國，教化可能性的內涵是什麼，實務雖然標準不一，近年來鑑定專家所認定的內涵為「犯罪行為人再度犯罪之風險、再教化、矯正、社會化之可能性」，這是吳敏誠更三審判決裡，鑑定人趙儀珊教授所採取的定義，參見臺灣高等法院102年度上重更（三）字第2號刑事判決。

在1976年 *Jurek v. Texas* 一案裡¹⁶⁹，德州法律要求陪審團決定「被告未來是否還會犯下暴力犯罪行為，對社會構成繼續的威脅？」被告主張人未來的行為無法被預測，但美國聯邦最高法院並不同意。美國聯邦最高法院認為，未來的行為的確不容易預測，但是並非完全不能預測。事實上，刑事司法制度有好多決定都是建立在對於未來犯罪行為的預測上，德州陪審團在死刑量刑程序裡所做的決定，與美國刑事司法體系向來做的各式預測並無差別¹⁷⁰。在1983年 *Barefoot v. Estelle* 一案中¹⁷¹，美國聯邦最高法院認定檢察官委任兩個精神科醫師鑑定被告的未來危險性合憲，即便美國精神醫學協會（American Psychiatric Association）在這個案件提出法庭之友的意見，主張對於未來危險性的長期預測不可靠，精神科醫師對於長期未來暴力（long-term future violence）的預測，三個案件中就有兩個的預測會出錯¹⁷²。但是美國聯邦最高法院堅持該協會有成員有不同意見，既然有醫生有意願與能力做這樣的預測，這樣的證據應該要被承認。如果真的有不可靠的證言，可以透過交互詰問來處理¹⁷³。法院的意見也暗示，如果一般人都可以做出這樣的觀察，學有專精的專家當然更可以¹⁷⁴。

由於美國聯邦最高法院的背書，未來危險性普遍規定在美國死刑州的法律裡。這個概念尚且分散在不同加重量刑情狀的規定中，譬如將被告的前科紀錄、被告在先前被監禁時並未被矯正，或仍然

169 See *Jurek v. Texas*, 428 U.S. 262 (1976).

170 *Id.* at 274-76.

171 See *Barefoot v. Estelle*, 463 U.S. 880 (1983).

172 See Amicus Brief of the American Psychiatric Ass'n for Petitioner at 14, *Barefoot v. Estelle*, 463 U.S. 880 (1983) (No. 82-6080), 1982 U.S. Briefs 6080 (1982)，轉引自 Meghan Shapiro, *An Overdose of Dangerousness: How 'Future Dangerousness' Captures the Least Culpable Capital Defendants and Undermines the Rationale for the Executions It Supports*, 35 AM. J. CRIM. L. 145, 146 (2008).

173 *Barefoot v. Estelle*, 463 U.S. 880, 899-903 (1983).

174 *Id.* at 896-97.

有暴力行為、被告威脅他人當作法定從重量刑情狀，這些規定背後的想法都是預設有這些狀況的被告具有未來危險性。被告毫無悔悟、或是避免警察出庭作證，甚至是參與犯罪集團，也會被用來證明被告具有未來危險性¹⁷⁵。作證被告有未來危險性的專家有時甚至不需要親自檢查犯罪行為人，只要回答檢察官提出的假設性的問題就好，美國聯邦最高法院在*Barefoot*案中肯定此種做法合憲，理由是這樣的作法很常見，死刑案件並無採用特殊法則的必要¹⁷⁶。

在死刑州的法律裡，未來危險性絕大部分作為判死的正面因素，被告若有未來危險性，不是因此具備判死的資格，就是增加判死的可能性，其重要性經常高於其他量刑因子¹⁷⁷。只是雖然未來危險性這個量刑因子受到美國聯邦最高法院的支持，也受死刑州的歡迎，但是，將未來危險性作為死刑量刑因子，卻一直受到醫學界與法學界的挑戰。除了醫學專家質疑司法心理學或精神醫學是否能夠正確地預測被告未來危險性之外，專家能否斷言被告有未來危險性，還是只能提供機率也是爭議之一¹⁷⁸。法學者的質疑是，在判斷被告是否該被量處死刑時，除了考量被告已犯下的犯罪行為之外，是否適當考量未來還沒有發生的行為¹⁷⁹？陪審團用未來被告可能做的事情作為死刑的從重量刑因子，判處被告死刑，是否讓死刑的裁量變得恣意？

175 See *Dawson v. Delaware*, 503 U.S. 159 (1992).

176 *Barefoot*, 463 U.S. at 903-04.

177 See Mark D. Cunningham, Thomas J. Reidy, & Jon R. Sorensen, *Assertions of "Future Dangerousness" at Federal Capital Sentencing: Rates and Correlates of Subsequent Prison Misconduct and Violence*, 32 LAW & HUM. BEHAV. 46, 47 (2008).

178 See CARTER, KREITZBER & HOWE, *supra* note 83, at 155.

179 RANDALL COYNE & LYN ENTZEROTH, *CAPITAL PUNISHMENT AND THE JUDICIAL PROCESS* 607-08 (4th ed. 2012).

(二) 本文意見

1. 人的未來行為難以被預測

回到臺灣的狀況。由於最高法院102年度台上字第170號刑事判決以及吳燦法官的後續判決對於如何進行教化可能性的實證調查，以及怎麼判斷程序的細節完全不講究，導致教化可能性的實務操作方式毫無一致性，終究引發臺灣社會對這個量刑因子的反彈，部分法院因此改變判斷方式，讓教化可能性不再扮演最後把關的角色。由於還是有法院繼續在死刑案件裡審查教化可能性，教化可能性用或不用或是怎麼使用，成為我國現行死刑量刑實務的最大變數。

上述問題雖然是現行實務判生判死標準混亂的重要原因，但其實並非不能處理。譬如：只要將相關的程序細節標準化，包括統一由專家鑑定，有個一致的判斷標準，理論上就可以解決，如果我們先不爭論判生判死的權限是否適當由法官移轉至專家。不過，即便如此，我們還是必須面對美國精神醫學界對於「人的未來行為是否可被預測」的根本質疑，倘若此類預測的準確度有限，是否能夠作為死刑的量刑因子？如果不能，我們還可以用什麼標準確認死刑的最後手段性？此外，美國的實務經驗也顯示，一旦臺灣引入模範刑法典的量刑模式之後，犯罪行為人的未來危險性，有可能被當作法定從重量刑情狀，也有可能被當作非法定的從重量刑證據，需要討論的問題，不只是一要不要保留教化可能性作為另一個審查層次而已。

回到概念的根本。先前提到，在我國，教化可能性原本只是法官量刑綜合判斷之後的結論，最高法院近年將教化可能性轉化為一個量刑因子，吳燦基準更進一步要求審判者在判死之前，必須對這個量刑因子進行實證調查，以確認死刑執行的必要性。最高法院的這些做法，相當程度與日本下級法院相同。依據學者謝煜偉的研究，由於日本最高法院為死刑案件創造出的永山基準只強調了罪責

均衡與一般預防作用，並沒有為改善更生等特別預防作用留有空間，因而日本下級審法院「想辦法從犯情與一般情狀等考量當中，找尋一些特別預防觀點的空間，以迴避死刑。也就是說，認為當被告仍帶有一絲改善挽回的餘地，可以透過其他刑事處罰加上制度外的措施，達成更生的可能性，就不要採取死刑（永久隔離以排害）的手段。¹⁸⁰」從刑事政策的角度來看，既然死刑不只有處罰的功能，也有排害的功能，那麼，倘若可證明被告還有更生的可能性，對社會不會造成危害，死刑的使用或許就沒有必要。事實上，從法社會學的角度來看，拿教化可能性作為不判死的理由也符合文化邏輯。鑑於每個死刑判決，每個支持死刑的主張都在說明犯罪行為人如何喪失人性¹⁸¹，那麼，只要犯罪行為人還可以被教化，表示他仍保有人性，法院就沒有判處死刑的必要。

只是，雖然最高法院的立意良善，其作法也符合大眾通念，但不代表這樣的概念是個適當可行的死刑篩選標準。最根本的問題還是在於人的未來行為是否能預測，然後拿預測的結果來正當化死刑的決定¹⁸²。我國教化可能性的概念雖然看起來比美國的未來危險性複雜，除了探究犯罪行為人再度犯罪之風險之外，尚且探尋犯罪行為人再教化、矯正、社會化的可能性。但是，對於絕大多數的法院而言，犯罪行為人未來對於社會有沒有再犯危險，還是教化可能性的判斷重點。特別當犯罪行為人已經先被證明情節最重大，也欠缺

180 謝煜偉，論「教化可能性」（註14），頁173-174。

181 相關討論參見李佳玟，死刑在臺灣社會的象徵意涵與社會功能，月旦法學雜誌，113期，頁117-18（2004年）。

182 讓問題更為複雜的是，即便不顧對於人未來行為之預測是否可信，一個人再犯性高與矯治可能性低若是因為國家投入矯治與更生資源不足，審判者於死刑量刑時，是否可以將外部資源不足的問題，歸責於被告，成為被告應被判死的理由？此外，在量刑時，被告再犯可能性的判斷是否要算上被告經過長期監禁的年紀？上述這兩個問題究竟是科學問題，政策問題，還是審判者個人刑罰哲學問題？如果認真地把外部資源欠缺與被告長期監禁後出獄的年紀算進去，死刑再多大程度還有必要？

具有份量的從輕量刑因子時，對社會看起來就會特別危險，這使得美國精神醫學界與法學界對於未來危險性的批評值得臺灣參考。

或許有人會拿美國聯邦最高法院在*Jurek*案的見解來支持「未來危險性」，本文認為，美國聯邦最高法院的說理其實很容易推翻。美國聯邦法院並沒有說錯，刑事司法體系中的確經常使用未來危險性的概念，包括被告是否要假釋，是否得到緩刑判決，這些都會涉及被告再犯可能性的預測。但是，假釋委員會高估了囚犯的再犯可能性，只是讓囚犯延後出獄，並不會增加囚犯的刑期。法官在考量是否給予被告緩刑時，高估了被告的再犯可能性，結果也只是讓她/他喪失短期的自由。相對之下，高估了死刑案件被告的再犯可能性，代價卻是被告的生命，不同脈絡的再犯預測以及危險預測並根本不能相提並論¹⁸³。

至於美國聯邦最高法院主張並不是所有專家都不能預測未來危險性，若個案的鑑定結果不可信，還是可以透過交互詰問來排除的說法，研究者Thomas Regnier質疑這樣的證據自始是否可以通過美國聯邦最高法院在*Frye v. United States*案¹⁸⁴，或是*Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals*案¹⁸⁵所建立之科學證據的證據法則。Frye法則是要求該科學證據必須廣泛地在該領域被接受，而Daubert法則進一步為科學證據設下更多的標準，包括聯邦法官對鑑定證據負把關義務，檢視專家證人提出的科學知識其推理及方法是否在科學上有效、是否與待證事項有關連並可信賴等等。因此，如果用在未來危險性的證據上適用Daubert法則，可以追問的是：（1）長期未來危險性的預測是否被測驗過？（答案：是的，他們被測驗過，並發現

183 Thomas Regnier, *Barefoot in Quicksand: The Future of "Future Dangerousness" Predictions in Death Penalty Sentencing in the World of Daubert and Kumho*, 37 AKRON L. REV. 469, 479-80 (2004).

184 See *Frye v. United States*, 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923).

185 See *Daubert v. Merrell Dow Pharm.*, 509 U.S. 579 (1993).

三分之二的錯誤率)；(2) 這個理論或是技術是否曾被同儕檢驗並出版發表過？(答案：是的，不少研究發現這個預測並不可靠)；(3) 這項技術已知或是潛在的錯誤率為何？(答案如同第一題)；(4) 這個技術或知識是否被相關的科學社群所接受(答案：不，相關的科學社群正式地拒絕這個技術)¹⁸⁶。

在 *Barefoot v. Estelle* 案之後的二十幾年裡，美國精神醫學協會持續反對在死刑量刑中使用「未來危險性」作為從重量刑事由，而美國心理學協會也有類似的結論¹⁸⁷。使用這類證據不僅違反科學證據的證據法則，Regnier認為，這類證據還很容易讓陪審團產生偏見，對於未來犯罪的恐懼，很容易壓過其他量刑因子的判斷，讓犯罪行為人沒有辦法得到一個公平的量刑程序¹⁸⁸。倘若長期研究人類行為的專家都沒辦法為法院做這樣的預測，不具專業背景的一般陪審員與法官更欠缺足夠的能力，只憑被告的某些行為（譬如：在法庭上對檢察官或是被害家屬噙聲，或甚至是被告有前科），就斷定被告未來有高度可能再犯，對社會具有未來危險性。美國聯邦最高法院的錯誤不只是在 *Barefoot* 案高估了精神科醫師的判斷能力，早在1976年時的 *Jurek* 案裡，就用似是而非的理由核准了這個從重量刑情狀。基於上述理由，以被告未來行為為預測為重點的從重量刑事由以及教化可能性的審查，都不應該存在於死刑量刑程序裡。

2. 以「更生改善可能性」的判斷取代「教化可能性」的審查？

面對「教化可能性」的各種問題，學者謝煜偉主張揚棄以監所設施處遇為依歸的「教化可能性」，改引入日本法院所進行的情狀鑑定，以判斷被告的「更生改善可能性」。他同樣反對透過科學鑑

¹⁸⁶ Regnier, *supra* note 183, at 495.

¹⁸⁷ CARTER, KREITZBER & HOWE, *supra* note 83, at 155.

¹⁸⁸ Regnier, *supra* note 183, at 487-88.

定的方式判斷犯罪行為人的教化可能性，不過他的理由主要在於委任專家實證地鑑定教化可能性，不過是利用科學鑑定的外衣掩蓋價值判斷。他認為，與其設定錯誤的鑑定命題，迫使鑑定人回答超越其能力的問題，不如承認其本質上就是一個由法官進行價值判斷的事項，從犯罪行為人本身的「更生改善」面向，探討有無迴避適用死刑的空間¹⁸⁹。本文同意他對於教化可能性鑑定的批評，現行的科學鑑定其實涵蓋了不少價值判斷，有些是鑑定人自己的價值判斷，有些則是加上法官的價值判斷，最終的結論其實是法官對於這一題的看法，卻常常被包裝在科學外衣下。

不過，學者謝煜偉建議引入的情狀鑑定制度，就其所要調查的內容來看：「指法院為了審酌各種量刑因素，包括動機、成長經歷、智識狀態等，對被告進行量刑或處遇方案，而囑託鑑定人以被告之犯罪要件事實以外的事實情狀為對象，以提供法院相關必要資訊之鑑定。情狀鑑定的鑑定事項相當多樣，可能包括被告性格、家庭環境、生活史、生活環境、犯罪動機及犯後心理狀態的調查、以及再犯可能性預測，甚至是處遇方案選擇、處遇成效等評估（包括今後更生重回社會的影響評估等）。¹⁹⁰」除了再犯預測之外，與本文主張在進行第二個階段的量刑審查時所建議的量刑報告接近，目的都是從社會人的角度，綜合考量被告的罪責程度。

日本當年之所以發展情狀鑑定制度，與其刑事程序上並未將定罪與量刑程序二分，因而無法引入美國的判決前量刑調查制度有關¹⁹¹。鑑於情狀鑑定容易與責任能力鑑定有所混淆，有時反而會對被告產生不利的效果¹⁹²；也鑑於本文主張定罪與量刑程序二分，並無日本實務當年必須寄生在既有制度，才能夠限縮死刑適用範圍的

189 謝煜偉，論「教化可能性」（註14），頁175。

190 謝煜偉，論「教化可能性」（註14），頁176。

191 謝煜偉，論「教化可能性」（註14），頁176-177。

192 謝煜偉，論「教化可能性」（註14），頁177。

問題，本文主張立法者應獨立建立一個被告責任能力調查之外的量刑報告制度，幫助審判者帶著同理又批判的眼光，深入理解「被告在其所存在的社會脈絡裡為何走到現在這一步」。不過，既然這個「被告更生改善可能性」的調查，就是本文主張之審判者在第二階段綜合量刑報告，審酌各種證據資料之後的結論，我國未來一旦引入模範刑法典的從重從輕死刑量刑模式，就不需要保留教化可能性（或是更生改善可能性）的調查，作為量刑審查的第三階段。

3. 死刑量刑適當性的審查

回歸一開始的提問，如果保存教化可能性概念的目的，是希望在判死之前，要求法官確認死刑的最後手段性，當以「未來危險性」為核心之教化可能性無法提供這樣的功能時，該用什麼做法取代？從重量刑情狀與從輕量刑情狀之兩個階段的審查是否就已經足夠？就此，本文建議參考美國喬治亞州的作法——於死刑案件上訴之後，喬治亞州最高法院必須審查死刑判決是否受到激情、歧視或是其他任意的因素影響，並且必須將本案與其他類似案件進行比較，看看量刑是否過度¹⁹³。如果引入臺灣，本文建議所有法院在判處死刑之前都對案件進行死刑適當性的審查，並與其他案件進行橫向比較，確認本案的死刑並沒有因為個案的激情因素，判得比其他類似案情的案件為重。若有犯罪行為人被過度處罰的疑問，法院應有把刑度減到無期徒刑的權限。上訴審法院雖然比較有餘裕去做這樣的衡量，但由原審法院自行反思整個案件的審理過程，橫向比較其他案件，仍對於死刑的量處提供必要的把關。

本文之所以建議引入此種死刑案件的最終審查，是因為當審判者只把心力集中在單一個案時，很容易在個案的小宇宙裡覺得犯罪行為人的罪刑已經達到均衡，特別當媒體沸沸揚揚地報導這個案件

¹⁹³ *Gregg*, 428 U.S. at 164-68.

的時候，犯罪行為人很容易看起來面目可憎，罪無可逭，死不足惜。但是如果在審判者在死刑量刑最後階段能夠重新檢視這個案件，並對比其他類似的案件，再次追問犯罪行為人之罪刑是否均衡，答案或許不那麼絕對。本文設計讓上級審或是下級審法院反身性地審查判斷死刑是否受到激情、歧視等因素的影響，使得量刑超過必要程度，就是想透過量刑的結構，督促審判者拉開與個案的距離，再度思考刑的公平性與罪刑均衡一事。

至於橫向比較「其他相類案件」時，要以哪些條件篩選出「相類案件」，的確是個難題。因為沒有兩個案件會完全類似，可能作為量刑的因素無窮，兩案的量刑結果不一，要說判處死刑的那個案件是受到歧視與激情的影響，的確有難度。本文的想法是，法院在審查時，至少應拿那些與本案「具備同樣的從重量刑因素，以及法定從輕量型因素」的案件進行比較。每個案件的條件確實不可能完全一致，針對那些不一致的部分，審判者可自問：那些不一致的部分，是否足以正當化不同的刑罰？刑罰之差異是否真的不是受到激情或歧視的影響？量刑是個困難的工作，但若罪刑均衡、量刑標準具有一致性，是刑事審判追求的目標，我們也只能面對這個難題，試圖透過量刑模式的建立，盡力協助裁判者於量刑時能冷靜地完成任務。

伍、結論

在2018年9月1日這一天，蔡英文政府無預警地執行其上任後的第一個死刑，殺害妻女的李宏基在那一天被執行槍決。輿論對這個死刑執行最大的質疑雖然在於執行時機，以及挑選死刑案件的標準，但更令人關心的是李宏基案的死刑量刑標準。他的律師於受訪時，講述李宏基背後的故事，那不只是死刑定讞判決裡所認定的家

暴傷人，把小孩當做財產任意取走生命，而且毫無悔意的故事，那也是一個不知為何走上婚姻失敗，家庭破碎，以至玉石俱焚的故事。那甚至是一個心灰意冷，想要透過司法自殺的故事¹⁹⁴。這個案件，李宏基在一審的時候被判處無期徒刑，法官嚴厲地譴責了李宏基，但也把他放在社會脈絡裡，看到他從原來是一個正常人，終至走上不歸路的過程。但到二審之後，由於李宏基在審判中嗆聲要傷害被害人家屬，李宏基在司法眼中變成是一個徹頭徹尾殘暴的人，二審法院改判死刑。即便最高法院將這個判決發回更審，更審法院在無量刑報告，也無任何鑑定報告的幫助下，以眼前看到的犯罪行為人之形象，判處被告死刑¹⁹⁵。

李宏基案例示了現行量刑模式的失敗——刑法第57條的盤點淪為過場，教化可能性毫無標準，到最後甚至被法院揚棄。但這個案例也告訴我們一個妥當的死刑量刑準則的重要性——倘若李宏基案採取本文所主張的死刑量刑模式，即便在從重量刑情狀裡，李宏基會因為殺害前妻與自己的小孩，被認定已具備其中一種從重量刑情狀，具有判死的資格。但是在從輕量刑情狀之層次裡，李宏基的生命故事將有機會透過量刑報告呈現出來，法官會有機會知道他面對婚姻關係變化的不知所措，他的失敗，他見不到女兒的痛苦。法庭上對於被害人家屬的嗆聲，很可能會被看作是一種意圖進行司法自殺的行為，而不是犯罪行為人毫無悔意，甚至是具有未來危險性的證明。即便在這個階段法官無法從活生生社會人的角度理解李宏基，那麼，為了小三殺害妻女，最終獲得無期徒刑的張鶴齡案，將

194 王吟芳，律師眼中的李宏基「被現實擊倒的爸爸」，蘋果即時新聞，2018年8月31日，<https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180831/1421885/>（最後瀏覽日：2018年9月8日）。

195 李宏基案的歷審判決為：臺灣高雄地方法院103年度重訴字第34號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院104年度上重訴字第6號刑事判決、最高法院105年度台上字第480號刑事判決、臺灣高等法院高雄分院105年度上重更（一）字第2號刑事判決、最高法院105年度台上字第3424號刑事判決。

會是一個本案該不該判死的重要對比。在本文所主張的死刑量刑準則裡，這個一心求死的李宏基，就不會被判死刑，也不會最終因為欠缺任何程序障礙（例如：聲請釋憲、非常上訴或再審），在面臨強大民怨時，被政府拿來祭旗。

死刑的執行，滿足大眾渴求正義的願望。李宏基案雖然在執行後的幾天引發社會討論，但恐怕很快就會被媒體遺忘，被眾人遺忘。無法抹滅的，是歷審判決的量刑落差。生與死的決定那麼重，死刑究竟是不是被告應得的懲罰，也只能一層一層地，講究各個程序細節地判定，盡人類智慧的可能性，讓這樣的決定不恣意。

參考文獻

1. 中文部分

- 王正嘉（2016），論死刑之裁量與界限：以兩公約與比較法為出發，臺大法學論叢，45卷2期，頁687-754。
- 王玉葉（2010），美國聯邦主義與民意對美國廢止死刑之影響，收於：歐美死刑論述，頁43-90，臺北：元照。
- （2010），美國最高法院審理死刑合憲性原則——試看Furman、Gregg與Atkins三案之軌跡，收於：歐美死刑論述，頁91-133，臺北：元照。
- （2010），死刑是否殘酷的刑罰——美國最高法院解釋的演進，收於：歐美死刑論述，頁173-218，臺北：元照。
- 朱學恒（2016），亂世殺人犯的免死金牌——有教化之可能，ETtoday論壇，2016年09月20日，<https://www.ettoday.net/news/20160920/778455.htm#ixzz5NEZDTXiW>。
- 余麗貞（2010），臺灣地區殺人案件量刑因素之研究，國立臺灣大學政治學研究所碩士論文。
- 吳燦（2016），刑罰裁量之正當程序——以死刑量刑為中心，法律扶助期刊，50期，頁32-36。
- 李世芬（2011），論死刑與無期徒刑之裁量標準，國立國防管理學院法律學研究所碩士論文。
- 李艾倫（2013），最高法院生死辯：死刑案件三審言詞辯論，全國律師，17卷7期，頁27-30。
- 李佳玟（2004），死刑在臺灣社會的象徵意涵與社會功能，月旦法學雜誌，113期，頁110-129。
- （2014），死刑案件的審判程序——從《麻州州長死刑諮詢委員會報告》談起，全國律師，18卷5期，頁72-88。

- 林山田（1977），論刑罰裁量——為紀念刑事法雜誌二十週年而作，刑事法雜誌，21卷1期，頁1-40。
- 林慈偉（2013），論公民與政治權利國際公約生命權概念於我國刑事司法之實踐，國立中正大學法律學研究所碩士論文。
- 高涌誠、黃淑芳（2015），死刑案件與兩公約，收於：與死刑拔河：死刑案件的辯護經驗與建議，頁51-91，臺北：新學林。
- 張升星（2015），謝依涵強盜殺人案判決評析——併論兩公約施行法之國內法效力，月旦裁判時報，38期，頁65-82。
- 許文彬（2017），「教化可能」豈是免死金牌，中國時報，2017年1月18日A10版。
- 黃致豪（2015），司法心理鑑定，收於：與死刑拔河：死刑案件的辯護經驗與建議，頁125-161，臺北：新學林。
- 廖福特（2014），「公民與政治權利國際公約」國內法化之影響：最高法院死刑相關判決之檢視，臺大法學論叢，43卷特刊，頁911-956。
- 劉邦繡（2015），生死判決與教化矯正合理期待可能之糾葛——從最高法院幾則生死判決改判案例談起，月旦裁判時報，40期，頁72-81。
- 蔡彩貞（2012），殺人罪量刑之實證研究，國立臺灣大學財務金融組碩士論文。
- 鄭政松（2014），唯處死刑或無期徒刑案件之量刑界限——以臺灣近十年相關殺人案件為例，國立臺北大學社會學研究所碩士論文。
- 賴宏信（2008），求刑與量刑歧異性與量刑標準之探索：以2001~2008年殺人罪為例，國立中央警察大學犯罪防治研究所碩士論文。
- 錢建榮（2013），最高法院死刑量刑辯論淪為「異鄉人」的審判！，全國律師，17卷7期，頁22-26。
- 謝煜偉（2013），簡評近來有關死刑案件之最高法院判決，全國律

師，17卷7期，頁5-21。

——（2014），「永山基準」臺灣版？——死刑量刑基準的具體化——最高法院102台上字第5251判決，台灣法學雜誌，249期，頁212-218。

——（2016），最高法院在死刑量刑判斷中的角色與功能：日本與臺灣的比較，收於：葉俊榮編，變遷中的東亞法院：從指標性判決看東亞法院的角色與功能，頁147-197，臺北：臺大出版中心。

——（2018），論「教化可能性」在死刑量刑判斷上的意義與定位——從最高法院最高法院102年度台上字第170號刑事判決到105年度台上字第984號判決之演變，臺北大學法學論叢，105期，頁133-186。

2. 外文部分

Carter, Linda E., Ellen Kreitzber, and Scott Howe. 2012. *Understanding Capital Punishment Law*. 3d ed. New York, NY: LexisNexis.

Coyne, Randall, and Lyn Entzeroth. 2012. *Capital Punishment and the Judicial Process*. 4th ed. Durham, NC: Carolina Academic Press.

Cunningham, Mark D., Thomas J. Reidy, and Jon R. Sorensen. 2008. Assertions of “Future Dangerousness” at Federal Capital Sentencing: Rates and Correlates of Subsequent Prison Misconduct and Violence. *Law and Human Behavior* 32:46-63.

Hoffmann, Joseph L. 2005. Protecting the Innocent: The Massachusetts Governor’s Council Report. *Journal of Criminal Law and Criminology* 95:561-585.

Kirchmeier, Jeffrey L. 1998. Aggravating and Mitigating Factors: The Paradox of Today’s Arbitrary and Mandatory Capital Punishment Scheme. *William & Mary Bill of Rights Journal* 6:345-459.

———. 2006. Casting a Wider Net: Another Decade of Legislative

- Expansion of the Death Penalty in the United States. *Pepperdine Law Review* 34:1-40.
- Latzer, Barry. 2002. *Death Penalty Cases: Leading U.S. Supreme Court Cases on Capital Punishment*. 2d ed. New York, NY: Butterworth-Heinemann.
- Massachusetts Court System Law Library. 2004. Governor's Council on Capital Punishment Final Report. In *Massachusetts Governor's Office*, <https://www.mass.gov/media/801591>.
- Pratt, John. 2000. Emotive and Ostentatious Punishment: Its Decline and Resurgence in Modern Society. *Punishment & Society* 2:417-439.
- Regnier, Thomas. 2004. Barefoot in Quicksand: The Future of "Future Dangerousness" Predictions in Death Penalty Sentencing in the World of Daubert and Kumho. *Akron Law Review* 37:469-507.
- Shapiro, Meghan. 2008. An Overdose of Dangerousness: How 'Future Dangerousness' Captures the Least Culpable Capital Defendants and Undermines the Rationale for the Executions It Supports. *American Journal of Criminal Law* 35:145-200.
- Simon, Jonathan, and Christina Spaulding. 1999. Tokens of Our Esteem: Aggravating Factors in the Era of Deregulated Death Penalties. Pp. 81-116 in *The Killing State: Capital Punishment in Law, Politics, and Culture*, edited by Austin Sarat. New York, NY: Oxford University Press.
- Steiker, Carol S., and Jordan M. Steiker. 2010. No More Tinkering: The American Law Institute and the Death Penalty Provisions of the Model Penal Code. *Texas Law Review* 89:353-421.
- . 2016. *Courting Death: The Supreme Court and Capital Punishment*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Tonry, Michael. 2013. Sentencing in America, 1975-2025. *Crime and Justice* 42:141-198.

Adopting Model Penal Code's Approach to Restructure the Capital Sentencing Scheme in Taiwan

*Chia-Wen Lee**

Abstract

In recent years, sentencing discretion in capital cases in Taiwan has been criticized as arbitrary. Although the Supreme Court in Taiwan has established guidelines to direct the death sentencing discretion, problems remain. This paper proposes adopting the capital sentencing scheme from the Model Penal Code drafted by the American Law Institute in 1962. Legislators should list aggravating circumstances in the Criminal Code as a prerequisite for each death sentence, and exemplify certain conditions as mitigating circumstances. Legislators should also establish a presentencing report system to help the court to understand the perpetrator and her/his crime(s). Since no scientists can reliably predict long-term future dangerousness, "the possibility of rehabilitation" should be abandoned when considering the death sentence. The court, instead, should compare this case to other, similar cases, and assess whether the death sentence in the case is affected by passions and prejudice, and thus excessive. Only when relevant factors have been thoroughly investigated and reviewed can the death sentence be legitimately rendered.

KEYWORDS: Sentencing Guideline for the Death Penalty, Model Penal Code, aggravating circumstances, mitigating circumstances, possibility of rehabilitation, the most serious crime.

* Professor of Law, National Cheng Kung University.